



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2015/13791 (00783.000022/2016-85)

Data do julgamento: 21/05/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ementa: Inobservância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC. Falhas na verificação do lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC. Liquidação dos direitos creditórios do Clássico FIDC pelo resultado líquido e não financeiramente. Delegação das atividades de cobrança e guarda física dos direitos creditórios cedidos aos FIDCs. Infração ao art. 38, incisos II, da Instrução CVM nº 356/01. Infração ao disposto no art. 38, inciso I, da Instrução CVM nº 356/01. Infração ao disposto no art. 38, inciso III da Instrução CVM nº 356/01. Infração ao disposto no art. 38, incisos IV e VI, da Instrução CVM nº 356/01 **Absoluções e Multas.**

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

1.1. A penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais) em razão da inobservância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso II, da Instrução CVM nº 356/01;

1.2. A penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais) em razão das falhas na verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso I, da Instrução CVM nº 356/01;

1.3. **Absolver** a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. da acusação de violação ao disposto no art. 38, inciso III da Instrução CVM nº 356/01; e

1.4. **Absolver** a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. da acusação de violação ao disposto no art. 38, incisos IV e VI, da Instrução CVM nº 356/01.

Presente o advogado Rafael Salles, representante da Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Em sua manifestação de voto, o Diretor Henrique Machado, não obstante acompanhar integralmente as considerações e as conclusões do voto do Relator, reiterou que a delegação da atividade não exclui a responsabilidade

administrativa do custodiante, sendo necessário avaliar, em cada caso, como ele se desincumbiu dessa responsabilidade supervisionando a atuação daqueles que subcontratou ou a quem as atividades foram delegadas.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 19/06/2019, às 14:11, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 19/06/2019, às 15:16, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 21/06/2019, às 12:10, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 21/06/2019, às 16:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0769781** e o código CRC **62EE9EB7**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0769781** and the "Código CRC" **62EE9EB7**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2015/13791

Reg. Col. nº 0347/2016

Acusado: Citibank DTVM S.A.

Assunto: Falha no desempenho das atividades sob a responsabilidade da instituição custodiante (art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM 356/01).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para apurar responsabilidade de Citibank DTVM S.A. (“Citibank” ou “Custodiante”) por irregularidades no desempenho da atividade de custodiante do Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“Clássico FIDC”)¹ e do Oboé Multicred – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“Multicred FIDC” e, quando em conjunto com Clássico FIDC, “FIDCs”)².

2. Tais irregularidades envolveriam (i) a não observância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios a serem cedidos aos FIDCs; (ii) a verificação de lastro dos referidos direitos creditórios; (iii) a realização de sua liquidação física e financeira; e (iv) a delegação das atividades de cobrança e guarda da documentação relativa aos direitos creditórios integrantes da carteira dos fundos, em suposta violação ao disposto nos incisos I a IV e VI do art. 38 da ICVM nº 356/01³.

¹Em 15.9.2011, o Clássico FIDC possuía 124 cotistas e patrimônio líquido de R\$ 35.977.751,14 (fls. 66), sendo que os principais cotistas individuais eram fundos administrados pela própria Oboé DTVM.

²Em 15.9.2011, o Multicred FIDC possuía 45 cotistas e patrimônio líquido de R\$ 16.596.737,99. Tal como no caso do Clássico FIDC, os principais cotistas individuais eram fundos administrados pela própria Oboé DTVM.

³Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: I – receber e analisar a documentação que evidencie o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; II – validar os direitos creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do fundo; III – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo instrumento de cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação; IV – fazer a custódia, administração, cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos direitos creditórios e demais ativos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

3. O presente processo originou-se a partir de inspeção (“Inspeção”) solicitada pela Gerência de Acompanhamento de Fundos – GIF no âmbito do Processo CVM nº RJ2011/11186⁴ e conduzida no período de 20.9.2011 a 19.10.2012 junto à Oboé DTVM S.A., aos fundos por ela administrados e seus prestadores de serviços, entre os quais, o Custodiante, tendo em vista o processo de intervenção direcionado às sociedades do grupo financeiro Oboé⁵, iniciado pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”) em 15.9.2011, por meio do Ato do Presidente nº 1.202 (fls. 48).

4. As irregularidades relativas à administração e gestão dos fundos de investimento foram objeto do PAS CVM nº RJ2014/2099, julgado em 1.12.2016, sob a relatoria do Diretor Roberto Tadeu. Naquela oportunidade, o Colegiado, acompanhando as razões de voto do Diretor Relator, decidiu pela condenação dos diretores responsáveis pela administração de carteira e do diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 387/03 no âmbito da Oboé DTVM S.A.⁶ por infração a diversos dispositivos das Instruções CVM nº 306/99, 356/01, 387/03 e 409/04.

II. FATOS

5. Após as diligências conduzidas no curso da Inspeção, a Superintendência de Fiscalização Externa (“SFE”) apontou a existência de irregularidades envolvendo os fundos de investimento administrados pela Oboé DTVM, dentre as quais determinadas falhas na atuação do Citibank, na qualidade de Custodiante do Clássico FIDC e do Multicred FIDC.

6. A carteira do Clássico FIDC era composta por direitos creditórios oriundos do financiamento concedido a usuários dos cartões de crédito do Sistema OboéCard, figurando como única cedente de créditos ao fundo a Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. (“Oboé Card”), ao passo que a carteira do Multicred FIDC era composta por direitos creditórios originários de empréstimos consignáveis em folha de pagamento,

integrantes da carteira do fundo; (...) VI – cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na conta de depósitos dos mesmos.

⁴ Solicitação de Inspeção nº 6/2011 (fls. 49)

⁵ Inicialmente, a decretação do regime de intervenção era direcionada à Oboé DTVM. No entanto, por meio de novos Atos do Presidente, o regime de intervenção foi estendido às seguintes empresas: Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Ato-Presi nº 1.201), Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. (Ato-Presi nº 1.203) e Companhia Investimento Oboé (Ato-Presi nº 1.204).

⁶ O recurso interposto em face da referida decisão encontra-se pendente de análise pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN (Proc. SEI 10372.000126/2017-66).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

representados por Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”) emitidas pelos devedores em favor da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“Oboé CFI” e, quando em conjunto com a Oboé Card, “Cedentes”), cedente exclusiva do Fundo.

7. Algumas das irregularidades apontadas pela SFI em seu Relatório de Inspeção⁷ dizem respeito justamente à delegação de determinadas atividades, originalmente atribuídas ao Custodiante, aos Cedentes, sendo elas a guarda física da documentação relativa aos direitos creditórios e a cobrança de tais créditos.

8. Também foi objeto de questionamentos pela SFI o modo pelo qual eram conduzidas as liquidações financeiras das operações de aquisições e baixas de direitos creditórios na carteira do Clássico FIDC, que, em sua maioria, não envolviam o recebimento de recursos pelo fundo, mas a compensação entre os valores devidos à Oboé Card em vista da cessão de créditos para compor a carteira do fundo e o montante a receber pelos pagamentos das faturas de cartão de crédito (*netting*).

9. Ainda no que diz respeito ao Clássico FIDC, apurou a SFI que, não obstante o art. 13⁸ de seu regulamento fixar os critérios de elegibilidade aplicáveis aos direitos creditórios a serem cedidos ao fundo, limitando a aquisição de créditos àqueles “Devedores que, no momento da aquisição pelo Fundo, não estejam inadimplentes com o FUNDO e/ou que não apresentem outros Direitos Creditórios vencidos e não pagos ao FUNDO” (fls. 336-346), das 96.115 faturas de cartão de crédito que compunham a carteira do fundo na data base de 30.10.2011, 56.381 estariam inadimplentes (fls. 78), além de terem sido identificados 22.528 créditos cedidos em duplicidade em 15.9.2011, o que evidenciaria possíveis falhas na validação dos critérios de elegibilidade, bem como na verificação do lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo.

10. Vale dizer que, segundo o apurado pela SFI, a verificação de lastro dos FIDCs era realizada, por procedimento amostral, por terceiro contratado, PC.C.P. Ltda., o qual apresentava os resultados apurados em relatórios trimestrais.

⁷ Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/Nº 11/2012 (fls. 54-306).

⁸ Art. 13. Para que possam ser adquiridos para a carteira do Fundo, os Direitos Creditórios deverão atender os seguintes critérios de elegibilidade (“Critérios de Elegibilidade”): I – devem ser referentes a Devedores que, no momento de aquisição pelo FUNDO, não estejam inadimplentes com o FUNDO e/ou que não apresentem outros Direitos Creditórios vencidos e não pagos ao FUNDO; e II- a aquisição de Direitos Creditórios poderá ser contratada sem a coobrigação do cedente, mas o cedente sempre será responsável pela legitimidade e pela formalização dos Direitos Creditórios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

11. Apresentadas, em linhas gerais, as conclusões apontadas no Relatório de Inspeção apresentado pela SFI, passo a descrever os fundamentos levantados pela Acusação em relação a cada uma das supostas infrações.

III. TERMO DE ACUSAÇÃO

III.1. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE NA VALIDAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CLÁSSICO FIDC

12. A primeira irregularidade objeto de análise pela Acusação diz respeito à observância dos critérios de elegibilidade na composição da carteira do Clássico FIDC, atribuição que, nos termos do art. 62 do regulamento vigente à época dos fatos⁹, caberia ao Custodiante.

13. Na visão da SIN, o fato de aproximadamente 60% das faturas de cartão de crédito originárias dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC estarem inadimplentes em 31.10.2011, representando quase 80% do montante total cedido ao fundo naquela data, somado à *“baixíssima qualidade [dos direitos creditórios], [que detinham] uma expectativa remota de adimplência por parte de seus devedores”* (fls. 492/494)¹⁰, representaria indício de que o Custodiante admitia a cessão de direitos creditórios ao fundo em desacordo aos critérios de elegibilidade previstos em seu regulamento.

14. A Acusação destacou, ainda, declaração prestada pelo próprio Custodiante em esclarecimentos à CVM¹¹, por meio da qual o Citibank afirmou ter sido notificado pelo interventor nomeado pelo BACEN acerca do equívoco nas datas de vencimento informadas no momento da cessão dos direitos creditórios, reconhecendo, no entanto, que *“mesmo considerando a data de vencimento equivocada, aqueles direitos creditórios já estavam vencidos a mais de 180 (cento e oitenta) dias”* (fls. 502-512).

⁹ Art. 62. O CUSTODIANTE é responsável pelas seguintes atividades: I – validar os direitos de crédito em relação aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos neste Regulamento; (...).

¹⁰ Nesse sentido, a Acusação cita informação prestada pela Massa Falida da Oboé DTVM em correspondência encaminhada à CVM em 13.8.2015, nos seguintes termos: *“Após a Intervenção, o patrimônio do Fundo foi analisado de forma pormenorizada pela equipe nomeada pelo Banco Central do Brasil. Essa análise diagnosticou que os ativos que compunham a carteira do Clássico detinham baixíssima qualidade, com uma expectativa de adimplência por parte de seus devedores, o que veio a se concretizar, conforme se constata a partir do montante vultoso referente à Provisão para Devedores Duvidosos – PDD, conforme quadro abaixo (...)”* (fls. 492/494).

¹¹ Petição protocolada em 10.7.2012 (fls. 502/512) em resposta ao Ofício/CVM/SFI/GFE-2/Nº054/2012 (fls. 495/501).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

15. Outra evidência levantada pela SIN seria o depoimento prestado por analista de sistemas da Oboé Card, em que este descreve o procedimento adotado na geração de arquivos eletrônicos das faturas de cartão de crédito cedidas ao fundo. De acordo com o depoente, em um primeiro momento, a orientação seria de que fossem selecionadas para compor tal arquivo apenas faturas com atraso de até 30 dias. Contudo, com o tempo, tal orientação teria sido flexibilizada.

16. Segundo a Acusação, a falha do Custodiante em validar os direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC restaria evidenciada com a comprovação de que determinados créditos eram cedidos ao fundo em duplicidade. Reproduzindo os termos do Relatório de Inspeção, esclareceu-se que *“uma fatura de cartão de crédito não paga, acrescida de juros e mora e com vencimento no mês seguinte, era cedida ao fundo simultaneamente à fatura do mesmo cliente relativa ao mês anterior, em diferentes termos de cessão. Assim o patrimônio do fundo ficava sobrevalorizado, não refletindo o real valor de sua carteira de recebíveis”*.

17. A possibilidade de cessão de direitos creditórios em duplicidade teria sido admitida por funcionários da Oboé Card¹² em depoimento à CVM.

18. Em manifestação preliminar apresentada no curso do presente processo, o Custodiante informou que a verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade seria realizada a partir dos arquivos eletrônicos disponibilizados pela Oboé Card com os dados dos direitos creditórios cedidos ao Fundo.

19. Ocorre que, segundo o Citibank, após a intervenção decretada pelo BACEN, teria se constatado que, *“no momento da cessão as informações acerca dos direitos creditórios eram alteradas, de modo que a administradora de cartões de créditos, Oboé Card, apresentava uma relação de direitos creditórios com datas de vencimento adulteradas”* (fls. 351-373), motivo pelo qual não seria possível ao Custodiante ter conhecimento de tais fatos.

¹² S.S.M afirmou em seu depoimento que *“não descarta[ria] a possibilidade que tal ‘dupla cessão’ de créditos tenha ocorrido, mesmo porque não havia no âmbito da empresa um procedimento padrão de controles que pudesse mitigar esse tipo de situação”* (fls. 517/521). Da mesma forma, A.R.S. declarou que *“por uma falha operacional do sistema ‘Back Office’ (...) ocorreu a seguinte situação: faturas de cartões de crédito de um mesmo devedor/cartão, mas relativas a meses diferentes, acabaram por compor os arquivos eletrônicos que eram gerados para ‘abastecer’ o Clássico FIDC; dessa forma, se determinado devedor tivesse em seu nome duas faturas vencidas e não pagas, relativas a meses diferentes, mas contemplando o mesmo valor principal da dívida, tais faturas acabaram por compor cessões distintas vendidas para o Clássico FIDC”* (fls. 513/516).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

20. Não obstante, na visão da Acusação, tal fato não afastaria as falhas do Citibank na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC. Não caberia ao Custodiante “*confiar cegamente*” (fls. 720) nos arquivos eletrônicos enviados pela Oboé Card, sendo possível a ele constatar a existência de direitos creditórios vencidos e não pagos, bem como de direitos creditórios em duplicidade, pela simples conferência amostral da documentação física de tais créditos, prática que, no entanto, não desempenhava, visto ter delegado a terceiros as atividades de verificação de lastro e guarda física dos direitos creditórios.

21. Por esta razão, a SIN concluiu que o Citibank teria descumprido o disposto no art. 38, inciso II, da ICVM 356/01.

III.2. FALHA NA VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CLÁSSICO FIDC

22. Também teriam sido identificadas pela Acusação irregularidades envolvendo os procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC, os quais, conforme apurado pela SFI, seriam desempenhados não pelo Custodiante, mas por terceiro por ele contratado para tanto.

23. Conforme esclarecido pela SIN, não seria objeto de questionamento a simples delegação da atividade de verificação de lastro pelo Custodiante, visto que a própria ICVM 531/11, que alterou as disposições da ICVM 356/01, admitiu a possibilidade de contratação de prestadores de serviços pela instituição custodiante para execução de tal atividade, previsão que, por força do princípio da retroatividade benigna, poderia ser aplicada à conduta do Citibank no presente caso.

24. Ocorre que, não obstante a contratação de terceiros, a responsabilidade administrativa do Custodiante pelo desempenho das atividades a ele atribuídas pela norma permanece, entendimento expresso na nova redação do §6º do art. 38 da ICVM 356/01¹³ e que já havia sido objeto de decisão pelo Colegiado da CVM¹⁴.

25. Portanto, diante da elevada inadimplência dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC e da cessão em duplicidade de faturas de cartões de crédito,

¹³ Art. 38. §6º. Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para a verificação de lastro dos direitos creditórios referidos nos incisos II e III e para guarda da documentação de que tratam os incisos VI e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade.

¹⁴ Nesse sentido, a Acusação mencionou o voto do então Presidente Marcelo Trindade no âmbito do Processo CVM nº RJ2004/6913, proferido em 4.10.2005.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

seria razoável que a verificação amostral dos documentos que garantem o lastro de tais direitos creditórios permitisse a identificação de tais irregularidades, o que, no entanto, não constou dos relatórios trimestrais elaborados pelo terceiro contratado pelo Custodiante.

26. Na visão da Acusação, a ausência de qualquer apontamento em tais relatórios decorreria de falhas no procedimento de verificação de lastro adotado pelo Custodiante e pelo terceiro por ele contratado. Isso porque, de acordo com depoimentos prestados pela “Gerente do Ambiente de Gestão de Ativos” da Oboé DTVM e funcionários do *back office* da administradora, nem o Custodiante nem o terceiro contratado teriam realizado qualquer diligência “*in loco*” nas dependências da Oboé DTVM para verificação do lastro dos direitos creditórios. Além disso, somente em uma primeira oportunidade teriam sido solicitadas cópias de faturas de cartão de crédito e os registros de determinados devedores, documentos que não foram novamente analisados em verificações posteriores¹⁵.

27. Ao esclarecer os critérios adotados para avaliar a inadimplência de determinado recebível integrante da carteira do Clássico FIDC, o Citibank declarou que “*a apuração do nível de inadimplemento dos recebíveis cedidos ao [fundo] competia ao Administrador [Oboé DTVM], encarregado de selecionar os créditos a serem adquiridos e negociar as condições com os cessionários, cabendo ao custodiante verificar o preenchimento dos critérios de elegibilidade*” (fls. 569-572). Acrescentou, ainda, que a verificação do inadimplemento de determinado crédito dependia de informações da Oboé Card.

28. Deste modo, concluiu a Acusação que não teriam sido adotados os procedimentos básicos para verificação dos documentos que representam o lastro dos direitos creditórios e que tanto o Custodiante quanto o terceiro por ele contratado teriam se valido de informações obtidas pela Oboé Card e pela Oboé DTVM, em violação ao disposto no inciso I, do art. 38 da ICVM 356/01.

III.3. IRREGULARIDADES NA LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM DIREITOS CREDITÓRIOS DO CLÁSSICO FIDC

¹⁵ De acordo com o depoimento de A.C.B.P., “*somente no primeiro trabalho de verificação de lastro procedido pela [P.W.], em meados de 2010, é que o auditor solicitou cópia de algumas faturas de cartão de crédito e os registros de alguns clientes junto ao SPC/Serasa, mas tal solicitação de documentos não voltou a ser feita nos trabalhos posteriores; (...) possivelmente (...) deixou de ser feita em trabalhos posteriores, dado que houve tratativas entre a [P.W.] e o diretor [J.], na qual este teceu uma série de considerações sobre as características operacionais do fundo*” (fls. 553-561).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

29. A terceira irregularidade apurada envolveria a liquidação das operações com direitos creditórios do Clássico FIDC. A análise dos extratos bancários fornecidos pelo Citibank, bem como as informações prestadas por ex-funcionários da Oboé Card e da Oboé DTVM, teriam revelado que, em sua maioria, as liquidações das operações do fundo se deram pela diferença (*netting*) entre o valor a receber em decorrência da “baixa” de direitos creditórios de sua carteira e o montante devido, correspondente a novas cessões de crédito pela Cedente.

30. A respeito de tal procedimento, vale destacar o seguinte trecho do depoimento prestado por ex-funcionário da Oboé Card:

“(...) aquele fundo [Clássico FIDC] adquiria periodicamente conjuntos de faturas de cartões administrados pela Oboé Card, sendo que tais faturas apresentavam um ‘ciclo de vida’ curto (em média um mês); tratava-se de um modelo baseado em renovações periódicas de operações, ou seja, sempre que havia o vencimento de um lote de faturas que estava na carteira do fundo, este lote retornava à Oboé Card e, ato contínuo, um novo lote de faturas era gerado e cedido ao fundo; (...) o fluxo financeiro sempre se dava pelo ‘netting’, salvo raras exceções” (fls. 517-521).

31. Na visão da Acusação, seria evidente a fragilidade de tal procedimento, uma vez que a ausência de liquidação financeira nas operações do fundo possibilitaria o alongamento dos prazos de vencimento dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC e teria por objetivo mitigar o risco de crédito na aquisição, para o fundo, de novos créditos. Tal fragilidade seria agravada, ainda, pelo conflito de interesses existente dada a posição da Oboé Card, que era, ao mesmo tempo, cedente dos direitos creditórios e responsável por sua cobrança junto aos devedores.

32. Segundo a SIN, além de contribuir para a elevada parcela de títulos em atraso integrantes da carteira do fundo, a atuação do Custodiante no sentido de permitir que fossem compensados os valores a receber dos devedores das faturas de cartão de crédito e o montante devido pela aquisição de novos direitos creditórios importaria descumprimento das disposições do “*Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios*”, segundo o qual “*todos os pagamentos devidos nos termos deste Contrato dever[iam] ser feitos em moeda corrente nacional (...)*” (Cláusula V – fls. 619-644).

33. Em manifestação preliminar, o Citibank alegou que justamente em razão das duas posições ocupadas pela Oboé Card – cedente e agente de cobrança e recebimento – esta seria também credora e devedora do Clássico FIDC, sendo natural a compensação de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

valores, além de estar prevista no art. 368 do Código Civil¹⁶. Ademais, argumentou que a previsão do art. 38, inciso III, da ICVM 356/01 não afastaria a possibilidade de adoção da prática de se compensar a dívida entre o fundo e terceiros.

34. Não obstante, a Acusação entendeu restar demonstrada a violação ao referido dispositivo legal, tendo proposto a responsabilização do Citibank.

III.4. DELEGAÇÃO INDEVIDA DAS ATIVIDADES DE COBRANÇA E GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOS DIREITOS CREDITÓRIOS

35. Por fim, as duas últimas infrações suscitadas pela Acusação dizem respeito à suposta delegação indevida de determinadas atividades atribuídas ao Custodiante, por força dos incisos IV e VI do art. 38 da ICVM 356/01, quais sejam, (i) a guarda dos documentos comprobatórios que evidenciam o lastro dos direitos creditórios; e (ii) a cobrança dos valores devidos aos FIDCs com fundamento nos direitos creditórios integrantes de sua carteira.

36. De acordo com as informações prestadas pelo Citibank, em ambos os FIDCs a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios caberia aos Cedentes, os quais teriam sido nomeados fiéis depositários, em observância à previsão dos respectivos regulamentos e em linha com a prática de mercado à época dos fatos. A nomeação dos Cedentes como fiéis depositários se justificaria, ainda, pelo fato de a Oboé Card e a Oboé CFI atuarem como agentes de cobrança dos fundos, dependendo, portanto, de tais documentos comprobatórios para o desempenho desta atividade.

37. Na visão da Acusação, no entanto, o fato de o Custodiante não manter sob sua guarda a documentação referente ao lastro dos direitos creditórios teria contribuído para as falhas na validação dos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do Clássico FIDC.

38. Nesse sentido, citou trecho da manifestação apresentada pela ASCORFIN no curso do presente processo, segundo a qual *“a simples verificação dos documentos relativos aos ativos do Fundo, ou seja, as Faturas (...) seria suficiente para perceber que as faturas cedidas poderiam causar risco ao patrimônio do Fundo”*, o que não teria ocorrido em razão da delegação de tal atividade à própria cedente.

¹⁶ Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

39. Quanto ao exercício da atividade de cobrança dos direitos creditórios, os regulamentos dos FIDCs já indicariam as Cedentes como “*agente de recebimento e cobrança*”¹⁷, além de detalhar o procedimento de cobrança a ser observado, que pressupunha, por sua vez, o trânsito de recursos advindos dos direitos creditórios em contas de titularidade das Cedentes, posteriormente repassados aos fundos.

40. Alegou o Custodiante que a contratação da Oboé Card e da Oboé CFI como agentes de cobrança se justificaria pelas características específicas dos FIDCs, uma vez que, por um lado, a Oboé Card, cedente do Clássico FIDC, possuiria a estrutura necessária para proceder à cobrança dos créditos originados em faturas de cartões de crédito, notadamente os documentos relativos a cada devedor, e, de outro, o procedimento de cobrança dos créditos integrantes da carteira do Multicred FIDC, envolvendo o desconto em folha de pagamento, dependeria da Oboé CFI, que detinha autorização das entidades consignantes para realizar tal desconto¹⁸.

41. Segundo a SIN, o fato de os pagamentos efetuados pelos devedores dos direitos creditórios integrantes das carteiras dos FIDCs transitar por conta de titularidade dos Cedentes, sem que fossem tomados os cuidados necessários para assegurar a segregação dos recursos relativos à carteira própria do Oboé Card e do Oboé CFI, traria riscos adicionais e desnecessários para os cotistas dos fundos.

42. Por estas razões, a Acusação concluiu que a delegação pelo Custodiante das atividades de cobrança e guarda dos documentos comprobatórios dos direitos creditórios representaria violação ao disposto nos incisos IV e VI, do art. 38 da ICVM 356/01.

43. Nos termos expostos, a SIN propôs a responsabilização de Citibank DTVM S.A., na qualidade de custodiante do Clássico FIDC e do Multicred FIDC, por suposta violação ao disposto no art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM 356/01.

¹⁷ Art. 46 do Regulamento do Clássico FIDC. A Cedente será responsável pelo recebimento e cobrança dos valores a serem recebidos por conta dos Direitos Creditórios.

Art. 35 do Regulamento do Multicred FIDC. A Cedente, contratada como Agente de Recebimento e Cobrança nos termos do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, será responsável pelo recebimento e cobrança dos valores a serem recebidos por conta dos Direitos Creditórios.

¹⁸ Haveria, ainda, outra dificuldade apontada pelo Citibank: a segregação dos valores devidos ao Multicred FIDC e aqueles devidos ao cedente. Isso porque nem toda a carteira de créditos consignados da Oboé CFI teria sido cedida ao Multicred FIDC. Assim, para cada entidade consignante, os valores retidos em folha de pagamento deveriam ser direcionados em parte para o Fundo e o restante para a carteira própria da Oboé CFI.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

44. Ao examinar a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu não ser possível imputar à instituição custodiante e aos seus diretores responsáveis uma das irregularidades inicialmente apontada pela SIN, referente ao extravio de cédulas de crédito bancário integrantes da carteira de fundo de investimento multimercado sob a custódia do Citibank, que, na visão da Acusação, importaria em violação ao disposto no art. 59, parágrafo único, inciso I, da ICVM 409/04.

45. Isso porque, ao contrário do regime previsto em relação aos fundos de investimento em direito creditório, com base no qual se impõe ao custodiante contratado “a custódia e a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios”, nos termos do art. 38, inciso V, da ICVM 356/01, no caso dos fundos de investimento multimercado, sujeitos às disposições da ICVM 409/04, não se atribuiria à instituição custodiante tal dever de guarda física dos títulos cartulares integrantes da carteira do fundo.

46. Nesse sentido, a norma cujo descumprimento teria se imputado ao Citibank e a seus diretores responsáveis – art. 59, parágrafo único, inciso I, da ICVM 409/04 – não guardaria relação com a conduta atribuída pela Acusação ao Custodiante. A referida norma determina que o contrato de custódia preveja que “*somente as ordens emitidas pelo administrador, pelo gestor ou por seus representantes legais ou mandatários, devidamente autorizado, podem ser acatadas pela instituição custodiante*”, ao passo que a suposta irregularidade imputada ao Custodiante diz respeito ao extravio de CCBs integrantes da carteira do FIM.

47. Em vista dos argumentos trazidos, a SIN decidiu acatar as sugestões da PFE (fls. 707), tendo aditado o termo de acusação, conforme versão constante das fls. 708-744, motivo pelo qual a análise desenvolvida pela Acusação a respeito do referido ilícito não se encontra refletida na descrição constante da seção III do presente relatório.

48. Em relação às demais imputações, a PFE entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos do art. 6º e o disposto no caput do art. 11, todos da Deliberação CVM nº538/08.

V. DEFESA

49. Em 30.3.2016, o Citibank apresentou suas razões de defesa, as quais passo a expor a seguir.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

50. Inicialmente, argumentou-se que as acusações formuladas pela SIN dirigir-se-iam à estrutura dos FIDCs, que, na visão da Acusação, refletiria situação de conflito de interesses, dadas as posições ocupadas pelas sociedades do Grupo Obóe como administradora dos fundos, cedentes dos direitos creditórios e agentes de cobrança. Em relação ao Custodiante, não teria sido indicada uma conduta violadora da regulamentação.

51. Ademais, não haveria, na regulamentação vigente à época, limitação a tal estrutura. Na realidade, um dos objetivos das alterações promovidas na ICVM 356/01 pela ICVM 531/11 seria justamente mitigar essas situações de conflito de interesses.

52. Outra circunstância a ser considerada seria a fraude conduzida pelo Grupo Oboé, a qual teria sido identificada tão somente quando da intervenção promovida pelo BACEN. Da mesma forma, a investigação conduzida pela SFI teria identificado que a Oboé Card fraudava deliberadamente as cessões de crédito feitas ao Clássico FIDC e as informações transmitidas ao Custodiante, de modo que este último também seria vítima desta fraude.

53. Passando à primeira das irregularidades apontadas, relativa à validação dos critérios de elegibilidade dos direitos creditórios do Clássico FIDC, o Acusado alegou que o critério a ser avaliado era a inexistência de dívida vencida e não paga com o fundo, de modo a assegurar que não fossem adquiridos direitos creditórios relativos a devedores que, no momento da cessão, já estivessem inadimplentes com o fundo em razão de dívida anterior, o que não se confundiria com a análise da adimplência do devedor.

54. Segundo o Acusado, haveria uma distribuição de atribuições entre administrador, a quem cabia a avaliação das “condições de cessão”, e custodiante do fundo, a quem se atribuía a verificação dos critérios de elegibilidade. No caso do Clássico FIDC, a adimplência do devedor era uma “condição de cessão” e a existência de dívida com o fundo era um “critério de elegibilidade”. No âmbito do PAS RJ2014/2099, a Oboé DTVM, administrador do fundo, teria sido acusada justamente por não ter verificado esta condição de cessão, isto é, a aquisição de direitos creditórios inadimplidos.

55. Sustentou, ainda, que nem mesmo se a verificação da condição de cessão fosse atribuída ao custodiante seria suficiente para identificar os problemas na carteira do Clássico, haja a vista a fraude perpetrada pela Oboé Card. Tal fato, inclusive, não teria sido levado em consideração pela Acusação, que ao apontar a aquisição de direitos creditórios em duplicidade como indício de não observância dos critérios de elegibilidade não teria considerado que as informações por ela avaliadas não coincidiram com aquelas transmitidas ao Custodiante pela Oboé Card à época da cessão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

56. Ademais, a existência de dois ou três direitos creditórios em relação ao mesmo devedor não revelaria qualquer indício de fraude, uma vez que seria comum que uma mesma pessoa fosse titular de mais de um cartão de crédito.

57. Quanto ao argumento da Acusação de que o Citibank teria “*confiado cegamente nos arquivos eletrônicos enviados pela Oboé DTVM*”, destacou que não caberia à instituição custodiante, no momento da cessão dos direitos creditórios, conferir a regularidade das informações prestadas pelo cedente, atribuição que, de acordo com a regulamentação, se daria somente com a verificação de lastro, *a posteriori*.

58. Questionou, ainda, a efetividade da adoção de tal procedimento, posto que, uma vez verificado que a Oboé Card adulterava as informações dos direitos creditórios, caso fosse confrontada com uma solicitação de envio de faturas, imaginar-se-ia que as informações ali constantes seriam alteradas para compatibilizá-las com o que constava no documento referente à cessão de crédito.

59. No que diz respeito à verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC, o Custodiante alegou novamente que as supostas falhas apontadas pela Acusação, em relação à atuação do terceiro contratado para desempenhar tal função, decorreriam da fraude praticada pelo Grupo Oboé.

60. Nesse sentido, seria “*a adulteração deliberada feita pela Oboé Card (...) e não verificada pela administradora do fundo, Oboé DTVM, quanto à data de vencimento dos direitos creditórios, que permitia, em primeiro lugar, a aquisição de ativos em desacordo com uma das condições de cessão prevista no regulamento*”.

61. Assim, na sua visão, eventual visita à sede da Oboé Card para a verificação de lastro dos direitos creditórios em nada contribuiria para inibir a prática da aludida fraude. Reiterou, ainda, que, por se tratarem de documentos unilateralmente produzidos pela administradora de cartão de crédito, as faturas também teriam pouca utilidade, pois, caso solicitadas, seriam igualmente modificadas pela Oboé Card.

62. Quanto à atuação do terceiro contratado para verificação do lastro dos direitos creditórios, esclareceu que este examinaria documentos relativos à comprovação de que o devedor era titular de cartão de crédito do sistema Oboé Card, os quais ofereceria segurança acerca da existência da relação contratual de utilização do cartão de crédito.

63. Passando ao tema da liquidação financeira dos direitos creditórios, que, no caso das operações envolvendo o Clássico FIDC seria realizada, em sua maioria, pela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

compensação de créditos e débitos junto à Oboé Card (*netting*), o Citibank argumentou que a compensação estaria prevista no art. 368 do Código Civil como modalidade de extinção das obrigações e se operaria de plano, desde que preenchidos os requisitos indicados no art. 369¹⁹ do referido diploma, sendo desnecessária qualquer autorização contratual prévia ou manifestação posterior das partes.

64. Contestou também a alegação da SIN de que a suposta impossibilidade de se operar a compensação teria como “*objetivo (...) mitigar o risco de crédito na aquisição, para o Fundo, de títulos de dívida*”, pois, a seu ver, a realização de duas transferências simultâneas em nada mitigaria qualquer risco da operação do fundo, da solvência de sua carteira ou da qualidade dos direitos creditórios adquiridos.

65. Por fim, em relação à guarda física da documentação e à cobrança dos direitos creditórios dos FIDCs, o Citibank sustentou que a delegação dessas atividades, preservada a responsabilidade da instituição custodiante quanto à sua regular prestação, não se traduziria em ilicitude, vez que não encontrava vedação normativa expressa à época dos fatos.

66. Com efeito, tratar-se-ia de prática de mercado amplamente admitida e fundamentada em entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM²⁰, no qual se admitiu a delegação da atividade de verificação de lastro a terceiro contratado, desde que observada a responsabilidade administrativa do custodiante.

67. Adicionalmente, recordou que a delegação estaria prevista nos regulamentos dos FIDCs, de modo que seria do conhecimento tanto dos cotistas como da própria CVM, além de se justificar dadas as características específicas dos direitos creditórios integrantes da carteira do Multicred FIDC e do Clássico FIDC.

68. Ademais, argumentou que o Parecer da PFE²¹ com base no qual se afirmou existir “*impeço jurídico à delegação da custódia de direitos creditórios, de determinado FIDC, a um terceiro não autorizado*”, citado na peça acusatória, foi a primeira ocasião na qual a CVM manifestou-se no sentido de sinalizar alguma restrição à delegação de atividades por instituições custodiantes de FIDCs.

69. Segundo o Acusado, até então, não se cogitaria quanto à impossibilidade de o custodiante delegar a terceiros determinadas atividades, haja vista a inexistência de

¹⁹ Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

²⁰ (Proc. CVM nº RJ2004/6913, Rel. Presidente Marcelo Trindade, j. em 4.10.2005.

²¹ MEMO/PFE-CVM/GJU-1/nº 129/2011 (fls. 550 a 552).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

restrição na ICVM 356/01. A prova de que não era clara a proibição à delegação de atividades pelo custodiante sob o regime da ICVM 356/01 seria justamente o fato de a PFE ter sido consultada sobre o tema, tendo se manifestado nos termos do referido parecer.

70. Ressaltou, no entanto, que tal manifestação não teria sido imediatamente tornada pública, mas o entendimento nela consubstanciado passou a ser adotado pela CVM. Diante das exigências de que os regulamentos se adequassem a este novo entendimento, teriam surgido pedidos de dispensa quanto ao cumprimento de certos requisitos da ICVM 356/01, notadamente para que fosse possível a delegação de atividades pelo custodiante.

71. No curso da análise de um desses pedidos de dispensa, objeto do Processo CVM nº RJ 2011/12712, a SIN teria apresentado manifestação, aprovada pelo Colegiado em 2.5.2012, no sentido de autorizar a delegação pretendida pelos requerentes, destacando, no entanto, eventuais situações de conflitos de interesses decorrentes da estrutura dos fundos, onde o originador ou cedente exerce atividades típicas do fundo.

72. Sustentou o Custodiante que a divulgação de tal entendimento no Ofício Circular/CVM/SIN/Nº 4/2012 teria conferido a publicidade necessária ao mercado quanto aos requisitos a serem observados em casos de delegação de atividades próprias da instituição custodiante de FIDCs. Em momento posterior, a ICVM 356/01 foi reformada, por meio da ICVM nº 531/13, de modo a restringir a delegação de atividades pelo custodiante a hipóteses específicas.

73. Diante desse histórico, destacou que *“a vedação à delegação pelo custodiante aos cedentes [...] não pode[ria] retroagir para alcançar a Defendente, que pautou sua conduta com base nas regras então em vigor, e na interpretação que sempre havia sido conferida à norma”* (fl. 795).

74. Por fim, arguiu-se que *“para haver violação de comando administrativo suscetível de punição, deve existir conduta dolosa, intencional, de descumprir-se a norma”* (fl. 797), características inexistentes no presente caso, uma vez que o Citibank teria adotado interpretação razoável das regras, compatível com o entendimento dos demais agentes de mercado à época dos fatos.

75. Nesse sentido, *“ainda que se venha a considerar a interpretação por ela adotada como incorreta, o caso não está a merecer a imposição de sanção, pois se trataria, quando muito, de erro de proibição”* (fl. 798).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

76. Em 26.4.2016, Citibank formulou proposta de celebração de termo de compromisso, comprometendo-se a pagar à CVM o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual corresponderia a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por cada uma das cinco infrações imputadas pela Acusação (fls. 813-817).

77. Em conformidade com o art. 7º, §5º²² da Deliberação CVM nº390/01, a PFE analisou os aspectos legais das propostas de termo de compromisso, concluindo pela existência de óbice em relação à proposta apresentada pelo Citibank, por entender que não teriam sido corrigidas as irregularidades mediante a indenização dos prejuízos diretos e individualizados apontados na peça acusatória, nos termos do art. 11, §5º, inciso II, da Lei nº 6.385/76²³.

78. Após o exame do parecer da PFE, o Comitê de Termo de Compromisso concluiu que, ainda que fosse superado o aludido óbice jurídico, a celebração de termo de compromisso seria inconveniente e inoportuna, visto que o presente caso demandaria um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento.

79. Em reunião de 6.9.2016, o Colegiado acompanhou o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso e deliberou, de forma unânime, a rejeição da proposta apresentada.

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

80. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 6 de setembro de 2016, o presente processo foi distribuído ao Diretor Gustavo Borba, nos termos do art. 3º da Deliberação CVM nº558/08²⁴.

81. Posteriormente, em 25.9.2018, em vista do término de seu mandato, o presente processo foi redistribuído a mim, conforme disposto no art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008²⁵.

²² Art. 7º, §5º. A Procuradoria Federal Especializada da CVM será ouvida sobre a legalidade da proposta.

²³

²⁴ Art. 3º. O sorteio de Relator far-se-á, de forma ostensiva, durante as reuniões ordinárias do Colegiado.

²⁵ Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

VIII. DILIGÊNCIAS ADICIONAIS E MANIFESTAÇÃO DO ACUSADO

82. Em 7.11.2018, proferi despacho solicitando à SIN a realização de diligências adicionais com o objetivo de “*explicitar a não observância pelo Citibank (...) dos critérios de elegibilidade previstos no regulamento do Clássico [FIDC]*” (fls. 1.008).

83. Em resposta, a área técnica conduziu análise complementar, cujo resultado restou consubstanciado na manifestação de 10.12.2018 e em mídia acostada aos autos (fls. 1.012-1.013v). Nesse sentido, a SIN informou ter confrontado todos os direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC em 13.9.2011, a partir de documento disponibilizado pelo interventor nomeado para atuar junto à Oboé DTVM, com as informações dos direitos creditórios em atraso obtidas pela SFI em seu trabalho de Inspeção.

84. Como resultado de tal comparação, teriam sido identificados “*centenas de direitos creditórios que ingressaram na carteira do Clássico FIDC em 13.9.2011 e que [seriam] referentes a devedores que estavam inadimplentes com o Fundo naquela data*” (fls. 1012v). De acordo com a SIN, 56,45% dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC em 13.9.2011 seriam relativos a devedores inadimplentes com o fundo naquela data.

85. Ressaltou, por fim, que, não obstante só ter sido possível realizar tal análise em relação à data base de 13.9.2011, haja vista as informações disponíveis nos autos, a seu ver, restaria demonstrado que o Custodiante não teria cumprido a sua obrigação de validar os direitos creditórios a serem cedidos ao Clássico FIDC à luz dos critérios de elegibilidade previstos em seu regulamento, em infração ao disposto no art. 38, inciso II, da ICVM 356/01.

86. Instado a se manifestar acerca de tais diligências²⁶, o Citibank reiterou alguns dos argumentos apresentados em sua defesa e acrescentou que as diligências conduzidas pela SIN não teriam sido suficientes para demonstrar que o Custodiante teria falhado em sua atuação ao não observar os critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do Clássico FIDC e permitir a aquisição de direitos creditórios relativos a devedores já inadimplentes com o fundo, visto que, segundo o Acusado, a área técnica teria novamente partido de premissa equivocada.

²⁶ Conforme despacho por mim proferido em 26.12.2018, publicado no Diário Oficial da União em 27.12.2018 (fls. 1.015-1.016).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

87. Isso porque as datas de vencimento constantes dos documentos analisados pela SIN não corresponderiam àquelas indicadas nos documentos enviados pela Oboé Card e consideradas pelo Custodiante na época das cessões. De acordo com tais documentos, por ocasião das cessões realizadas em 13.9.2011, os direitos creditórios relativos a devedores que já integravam a carteira do fundo ainda não estariam vencidos, o que ocorreria apenas em 15.9.2011.

88. Ressaltou o Acusado que as verdadeiras datas de vencimento dos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo só teriam sido identificadas após a intervenção e liquidação decretada pelo BACEN, uma vez que a fraude conduzida pelo Grupo Oboé consistiria justamente na alteração das datas de vencimento dos créditos da Oboé Card antes de sua cessão ao Clássico FIDC.

89. Em vista da alegada fraude, da qual também teria sido vítima, não seria possível ao Custodiante identificar qualquer descumprimento aos critérios de elegibilidade do fundo.

90. Por fim, alegou que a conferência amostral da documentação física que, segundo a Acusação, poderia ter sido conduzida pelo Citibank para verificar a existência de direitos creditórios vencidos ou em duplicidade na carteira do fundo se referiria a outra atribuição do custodiante, a verificação de lastro, a qual só seria realizada quando tais créditos já integrassem a carteira do fundo e não no momento de sua cessão.

91. Nesse sentido, afirmou que *“não se pode[ria] confundir as duas atribuições e exigir da custodiante que, na validação dos critérios de elegibilidade, tivesse realizado uma prévia verificação de lastro, por amostragem para investigar se as informações que constavam dos documentos fornecidos pela cedente eram compatíveis com as informações que viessem a ser extraídas de outros documentos solicitados”*.

92. Ademais, sustentou o Acusado que, ainda que tal verificação fosse conduzida no momento da cessão, a documentação física a ser analisada consistia nas faturas de cartões de crédito, documento unilateral emitido pela Oboé Card, que, em última análise, poderia ser igualmente fraudado.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2015/13791

Reg. Col. nº 0347/2016

Acusado: Citibank DTVM S.A.

Assunto: Falha no desempenho das atividades sob a responsabilidade da instituição custodiante (art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM 356/01).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) tem por objeto a apuração de responsabilidade de Citibank DTVM S.A. (“Citibank” ou “Custodiante”) por irregularidades no desempenho da atividade de custodiante do Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“Clássico FIDC”) e do Oboé Multicred – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“Multicred FIDC” e, quando em conjunto com Clássico FIDC, “FIDCs”).
2. De acordo com a acusação formulada pela Superintendência de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), tais irregularidades envolveriam (i) a não observância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC; (ii) falhas na verificação de lastro dos referidos direitos creditórios; (iii) a liquidação das operações do Clássico FIDC pelo resultado líquido entre a “baixa” de direitos creditórios da carteira do fundo e a aquisição de novos ativos junto ao cedente (*netting*); e (iv) a delegação das atividades de cobrança e guarda da documentação relativa aos direitos creditórios integrantes da carteira dos FIDCs.
3. Por ocasião da inspeção que deu origem ao presente processo, conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) junto aos FIDCs e aos seus prestadores de serviços (“Inspeção”), foram identificadas, ainda, falhas substanciais na administração e na gestão dos fundos, sob a responsabilidade da Oboé DTVM S.A. (“Oboé DTVM”), as quais foram objeto do PAS CVM nº RJ2014/2099, julgado em 1.12.2016, sob a relatoria do Diretor Roberto Tadeu.
4. Naquela oportunidade, verificou-se que a estrutura inerentemente conflituosa prevista para os fundos sob a administração da Oboé DTVM – entre os quais os FIDCs –



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

somada às falhas nos controles internos mantidos pela administradora e à ausência de segregação das funções de administração de carteira das demais atividades desempenhadas pelo Grupo Oboé teriam permitido, entre outras irregularidades, que fossem cedidos à carteira do Clássico FIDC direitos creditórios em duplicidade ou relativos a devedores inadimplentes, sem que fosse realizado, em contrapartida, qualquer provisionamento para créditos de liquidação duvidosa e sem a correta divulgação aos investidores do nível de inadimplência do fundo.

5. Tal cenário culminou com a situação de deterioração dos ativos integrantes da carteira dos fundos, identificada após a decretação da intervenção pelo Banco Central, e, por conseguinte, com os severos prejuízos suportados pelos seus cotistas. No caso do Clássico FIDC, por exemplo, segundo informações prestadas pela Oboé DTVM após a intervenção, o patrimônio líquido do fundo em 14.5.2012 representaria 12% do declarado em 14.9.2011, data anterior à decretação da intervenção.

6. Diante deste contexto, o Colegiado decidiu pela condenação dos diretores responsáveis pela administração de carteira e do diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 387/03 no âmbito da Oboé DTVM por infração a diversos dispositivos das Instruções CVM nº 306/99, 356/01, 387/03 e 409/04.

7. Resta avaliar a conduta do Citibank no desempenho de suas atividades como custodiante dos FIDCs. Tal exame foi apartado do julgamento do PAS CVM nº RJ2014/2099 em razão da apresentação de proposta de termo de compromisso no curso da investigação, posteriormente rejeitada pelo Colegiado em reunião de 14.4.2015.

8. Antes de passar à análise de cada uma das infrações imputadas pela Acusação, gostaria de apresentar considerações preliminares acerca do papel da instituição custodiante nas atividades relacionadas à administração dos fundos de investimento.

9. Vale ressaltar que a responsabilidade do custodiante de FIDCs já foi objeto de análise pelo Colegiado da CVM por ocasião do julgamento do PAS RJ2011/10415 (“Caso FIDC Panamericano”) e do PAS RJ2013/5456 (“Caso FIDC Union”), realizados, respectivamente, em 2.12.2014 e 20.10.2015.

10. Considerando, no entanto, que em decisão recente (24.4.2018) proferida no julgamento de recurso interposto pela instituição custodiante no Caso FIDC Union, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), por maioria, reverteu



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

parte das condenações impostas pelo Colegiado ao Banco Bradesco S.A.¹, entendo oportuno expor o meu posicionamento sobre o tema.

11. Nos termos do art. 24 da Lei nº 6.385/76², a custódia de valores mobiliários compreende “o depósito para guarda, recebimento de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou reembolso, e exercício de direitos de subscrição”, estando tal atividade sujeita à prévia autorização desta CVM, a quem cabe regular o seu exercício.

12. Em um primeiro momento, tal atividade encontrava-se disciplinada na ICVM 89/88, a qual dispunha, ainda, sobre a prestação de serviços de ações escriturais e de emissão de certificados de valores mobiliários. Na esteira das discussões, pós crise de 2008, sobre a relevância das infraestruturas de mercado para a mitigação de riscos³, promoveu-se reforma no regime regulatório envolvendo tais atividades, que passaram a

¹ Processo 10372.000415/2016-84 (Recurso 14.149), julgado na 412ª Sessão, realizada em 24.4.2018 (Acórdão CRSFN 77/2018). O referido processo tinha por objeto a apreciação de recursos interpostos por Banco Bradesco S.A., Oliveira Trust DTVM S.A. e Mauro Sérgio de Oliveira. Em relação a Oliveira Trust DTVM S.A. e Mauro Sérgio de Oliveira foram mantidas as condenações impostas pelo Colegiado da CVM no julgamento do PAS RJ2013/5456. Já no que diz respeito ao Banco Bradesco, na qualidade de custodiante, por maioria, foi dado provimento ao recurso de modo a reverter as condenações relativas à (i) delegação aos cedentes da atividade de guarda dos documentos que evidenciaram o lastro dos direitos creditórios (vencidos os Conselheiros Alexandre Graziano, Ana Maria Melo e Otto Eduardo Fonseca); e (ii) liquidação de direitos creditórios por compensação parcial ou total e não financeiramente (vencidos os Conselheiros Adriana Dullius, Antonio Augusto de Sá e Sérgio Cipriano). Por unanimidade, manteve-se a condenação do Banco Bradesco em relação infração de não manutenção da documentação dos direitos creditórios atualizada e em perfeita ordem. Em suas razões de voto, o Conselheiro Relator Carlos Pagano defendeu uma melhor delimitação dos deveres conferidos a cada um dos prestadores de serviços de fundos de investimento e, no que diz respeito à atuação do custodiante na estrutura dos fundos, adotou interpretação mais formal acerca das atribuições conferidas a este prestador de serviço, comparando-as a uma atividade registral, tal como aquela desempenhada pelas Juntas Comerciais.

² Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores mobiliários, cujo exercício será privativo das instituições financeiras, entidades de compensação e das entidades autorizadas, na forma da lei, a prestar serviços de depósito centralizado. Parágrafo único. Considera-se custódia de valores mobiliários o depósito para guarda, recebimento de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou reembolso, e exercício de direitos de subscrição, sem que o depositário, tenha poderes, salvo autorização expressa do depositante em cada caso, para alienar os valores mobiliários depositados ou reaplicar as importâncias recebidas.

³ Conforme se verifica a partir do Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2013, na esteira das discussões pós crise de 2008, buscou-se aperfeiçoar infraestruturas capazes de mitigar riscos decorrentes dos processos de inovação por meio da “imobilização dos ativos”, a qual se daria pelo depósito dos ativos em um depositário central, entidade encarregada, fundamentalmente, de prestar serviços de custódia centralizada de ativos. Até a edição da Lei nº 12.810/2013, o depósito central de ativos existia apenas em relação às ações, nos termos do art. 41 da Lei nº 6.404/76.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

ser disciplinadas separadamente, nos termos das ICVMs 541 (depósito centralizado), 542 (custódia) e 543 (escrituração).

13. Neste cenário, buscou-se estabelecer uma cadeia de obrigações e de responsabilidades envolvendo escrituradores, custodiantes e depositários centrais, de modo a assegurar segurança, eficiência e confiabilidade às negociações de valores mobiliários. Ao custodiante a ICVM 542 impôs, entre outras obrigações, a segregação dos ativos custodiados em relação às contas e posições de titularidade do próprio custodiante e a manutenção de procedimentos e rotinas formais de controles, inclusive na hipótese de contratação de terceiros para prestação de serviços⁴.

14. Ocorre que, não raro, a atividade exercida pelo custodiante junto aos fundos de investimento abarca outras atribuições que não somente a custódia pura e simples de valores mobiliários⁵. Assim, em sua atuação, tais participantes deverão observar tanto as disposições da ICVM 542/13 – inclusive em relação aos requisitos a serem preenchidos para o exercício de tal atividade – quanto as obrigações impostas pela regulamentação específica dos fundos de investimento, notadamente neste caso a ICVM 356/01.

15. No que diz respeito à estrutura dos fundos de investimento, em linhas gerais, entendo que o objetivo regulatório ao incluir a previsão de contratação de terceiro para exercer o papel de custodiante – cuja atividade, vale dizer, poderia ser desempenhada pelo próprio administrador fiduciário, nos termos da ICVM 555/14⁶ e da ICVM 356/01⁷ – seria

⁴ Em seu Código de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, a ANBIMA descreve com maior detalhe as atividades de guarda, liquidação e monitoramento de eventos de ativos financeiros, bem como os controles a serem observados pelo custodiante visando à segregação de posições de ativos. Vide http://www.anbima.com.br/pt_br/autorregular/codigos/servicos-qualificados.htm> Acesso em 19.3.2019.

⁵ Nesse sentido, vale destacar o seguinte trecho do Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2013: “É importante destacar que a regulamentação das atividades de custódia, no presente contexto, não corresponde exatamente ao conjunto de atividades dos custodiantes de fundos de investimento, conforme previsto na Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004. Os custodiantes de fundos de investimento devem, ao prestar os serviços propriamente de custódia de valores mobiliários, observar o regime previsto na norma que ora se propõe. No entanto, é importante destacar que suas atividades, não raro, vão além da custódia pura e simples, abrangendo serviços correlatos”.

⁶ Art. 79. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços de administração, conforme mencionado no art. 78, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a contratação dos serviços de auditoria independente referida no art. 65 e, quando não estiver o administrador devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação, os serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI do § 2º do art. 78.

⁷ Tanto na redação original da ICVM 356/01 quanto após os ajustes implementados a partir da ICVM 531/2013 previu-se a possibilidade de, preenchidos os requisitos da ICVM 542/13, o administrador



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

assegurar maior confiabilidade quanto ao registro e guarda dos ativos ao agregar outro nível de controle à estrutura dos fundos, evitando, principalmente, situações de conflito de interesses e fraudes na administração destes ativos.

16. Dito de outro modo, ao autorizar o exercício da atividade de custódia por outro participante de mercado, distinto do administrador fiduciário, buscou-se estimular uma estrutura de controles mútuos e independentes no âmbito dos fundos de investimento. Até mesmo porque a contratação de instituição custodiante envolve a assunção de custos para os fundos, os quais se justificam, propriamente, em razão dos ganhos de governança que se espera advir da atuação deste prestador de serviço.

17. Antecipando algumas considerações apresentadas pelo Citibank em suas razões de defesa, esclareço, desde logo, que, a meu ver, a preocupação regulatória de atribuir ao custodiante a função de *gatekeeper* na estrutura dos FIDCs já se encontrava, em maior ou menor medida, refletida na redação original da ICVM 356/01.

18. Ainda assim, há que se reconhecer a importante evolução na regulação dos fundos de investimento em direitos creditórios, vivenciada a partir da reforma de 2013 (ICVM 531/13), a qual teria sido destacadamente motivada pela experiência adquirida pela CVM com a supervisão da indústria de FIDCs, conforme ressaltado no edital de audiência pública SDM nº 05/12⁸.

19. Com efeito, verifica-se que as principais alterações inseridas a partir da referida reforma guardam relação com fragilidades identificadas em fundos de investimento cuja estrutura previa a concentração de funções relevantes por um mesmo participante, a propiciar eventuais situações de conflito de interesses, bem como a diluição de responsabilidades entre os prestadores de serviço do fundo⁹, tal como ocorreu nos Casos FIDC Panamericano e FIDC Union.

fiduciário exercer a atividade de custódia, nos termos do art. 39 da ICVM 356/01. Vale ressaltar, no entanto, que houve uma tentativa de vedar tal cumulação de funções pelo administrador fiduciário por ocasião da edição da ICVM 442, de 8.12.2006, a qual foi rapidamente revertida por meio da edição da ICVM 446, de 19.12.2006. Neste curto intervalo de tempo, vigorou a seguinte norma “Art. 39. §2º. É vedado ao administrador prestar serviços de custódia para o fundo, devendo ser contratada instituição credenciada na CVM para a prestação deste serviço que não integre o mesmo grupo econômico do administrador”.

⁸ “A proposta contempla também alterações decorrentes da experiência adquirida pela CVM com a contínua supervisão da indústria de FIDC e com a aplicação da Instrução CVM nº 356, de 2001, buscando inibir situações percebidas como potencialmente negativas”.

⁹ “A Minuta tem por objetivo aperfeiçoar aspectos da norma, sobretudo quanto: i) à mitigação de estruturas que propiciam a ocorrência de conflito de interesses, em que a concentração indevida de funções por um



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

20. De modo a enfrentar tais fragilidades, previram-se novos mecanismos de controle a serem observados pelo administrador fiduciário e pelo custodiante, com uma melhor delimitação das atribuições e responsabilidades conferidas a cada um destes prestadores de serviço. Estabeleceram-se, ainda, limitações a cumulação de atividades por um mesmo participante ou por parte a ele relacionada.

21. As alterações promovidas por ocasião da referida reforma alinham-se às políticas regulatórias adotadas em outras jurisdições no que diz respeito aos padrões a serem observados no exercício da atividade de custódia no âmbito dos fundos de investimento, conforme se extrai das conclusões expostas no relatório final divulgado pela *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) em novembro de 2015¹⁰.

22. A partir de pesquisa conduzida junto a países membros do Comitê de Gestão de Investimento (C5)¹¹, a IOSCO apontou entre os padrões a serem observados pelos custodiantes justamente (i) a segregação dos ativos relativos aos fundos de investimento dos ativos do próprio custodiante, da “*responsible entity*”¹² ou de outros fundos; (ii) a relevância da independência operacional do custodiante ao qual é conferida a obrigação de custódia dos valores mobiliários; e (iii) a diligência a ser observada na indicação de prestadores de serviço para os fundos, não somente pelo administrador fiduciário como também pelo próprio custodiante. Tais recomendações estão associadas aos principais riscos identificados nas jurisdições consultadas.

mesmo participante ou por partes a ele relacionadas compromete a boa governança dos FIDC; e ii) ao aperfeiçoamento dos controles por parte do administrador e dos principais prestadores de serviços aos FIDC, com a definição mais clara da atuação e de responsabilidades dos atores desse mercado”.

¹⁰ Vide < <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD512.pdf> > Acesso em 19.3.2019.

¹¹ Membros do Comitê que participaram da pesquisa: Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Jersey, Luxemburgo, México, Holanda, Nigéria, Panamá, Portugal, Romênia, Cingapura, África do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos (Commodity Futures Trading Commission - CFTC e Securities and Exchange Commission - SEC).

¹² De acordo com o Glossário que acompanhou o relatório divulgado pela IOSCO, o termo “*responsible entity*” refere-se a “*entity or entities that has / have overall responsibility for the management and performance of the functions of the CIS, in particular, its compliance with the legal and regulatory framework in its respective jurisdiction*”. Esclarece-se, ainda, que “[t]he identification of the ‘*responsible entity*’ may vary among jurisdictions and types of CIS. In some jurisdictions, the responsible entity could be the management company of the CIS itself. In others, the management company may play a role in carrying out the principles, but may be overseen by an independent body (e.g. board of directors, depositary or custodian). For CIS which are structured as a unit trust, the responsibilities for the performance of the functions of the CIS and compliance with legal and regulatory framework could rest with both the management company and the Trustee”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

23. No que diz respeito à delegação de funções atribuídas ao custodiante, vale ressaltar que, ao mencionar as iniciativas regulatórias mais recentes na Europa envolvendo o papel do custodiante, o relatório esclarece que foram introduzidas novas exigências para que seja possível tal delegação, em especial no que diz respeito aos requisitos a serem preenchidos pelo destinatário da delegação¹³.

24. Retornando ao caso concreto, é certo que, à luz das disposições da ICVM 356/01 “pós-reforma”, a estrutura prevista para os FIDCs sob a administração da Oboé DTVM não estaria aderente ao arcabouço regulatório. Contudo, não era este o cenário à época dos fatos, motivo pelo qual o exame da conduta do Citibank deverá levar em consideração os preceitos normativos então vigentes.

25. Isso não significa que, diante de uma estrutura potencialmente conflituosa, com atividades concentradas em um único participante ou em sociedades do mesmo grupo econômico – tal como seria o caso dos fundos administrados pela Oboé DTVM –, os prestadores de serviço “independentes” não dispusessem, já à época dos fatos, de mecanismos de controles capazes de mitigar os riscos decorrentes de tal estrutura, notadamente o risco de fraude.

26. Conforme ressaltado anteriormente, entendo que mesmo na redação original da ICVM 356/01 o papel de *gatekeeper* atribuído à instituição custodiante já se encontrava refletido nas atividades e controles a serem desempenhados por este prestador de serviço.

27. Feitas estas considerações, passo à análise de mérito do presente processo.

¹³ “The AIFMD and UCITS V introduce new requirements in relation to the delegation of safekeeping duties by a depositary to sub-custodians. The new requirements generally relate to the operation of sub-custodians and require that sub-custodians: (i) have structures and expertise that are adequate for the safekeeping of the assets that are entrusted to them; (ii) are subject to effective prudential regulation and regulatory supervision; (iii) are subject to an external periodic audit; and (iv) take all necessary steps to ensure that in the event of the sub-custodians’ insolvency that the assets of the AIF/UCITS are not available for distribution to creditors. Furthermore, the depositary should delegate its safekeeping duties unless it can demonstrate that: (i) there is an objective reason for the delegation; (ii) it has exercised due skill and care in the selection and ongoing monitoring of the sub-custodian; and (iii) the delegation is not made with the intention of avoiding the requirements of the AIFMD/UCITS V”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

II. MÉRITO

II.1. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE NA VALIDAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CLÁSSICO FIDC

28. A primeira acusação a ser examinada diz respeito a não observância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios por ocasião de sua cessão à carteira do Clássico FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso II, da ICVM nº 356/01.

29. Nos termos do art. 13 do regulamento do Clássico FIDC (fls. 336-346)¹⁴, seriam dois os critérios de elegibilidade a serem considerados na aquisição de direitos creditórios pelo fundo: (i) os créditos deveriam ser relativos a Devedores que, no momento da cessão, não estivessem inadimplentes com o fundo; e (ii) o cedente deveria responder pela legitimidade e pela formalização dos direitos creditórios, admitindo-se, no entanto, a aquisição de direitos creditórios sem a coobrigação do cedente.

30. Na visão da Acusação, haveria indícios de que o Citibank teria permitido a aquisição de direitos creditórios relativos a devedores inadimplentes com o fundo, em inobservância, portanto, ao primeiro critério de elegibilidade descrito em seu regulamento.

31. A amparar tal conclusão foram levantados os seguintes elementos: (i) a alta taxa de inadimplência dos direitos creditórios cedidos à carteira do Clássico FIDC na data base de 13.9.2011, imediatamente anterior à decretação da intervenção na Oboé DTVM; (ii) depoimentos prestados por funcionários ligados à Oboé Card, cedente dos direitos creditórios, reconhecendo terem sido selecionados créditos já vencidos para serem cedidos ao fundo; (iii) a existência de direitos creditórios em duplicidade em sua carteira; e (iv) declaração prestada por representantes do Citibank em assembleia geral de cotistas realizada em 17.11.2011 afirmando nunca ter sido realizada “a análise do perfil dos devedores cedidos quanto à sua adimplência” (fls. 523-533).

32. Todos esses elementos, especialmente quando considerados em conjunto, revelam a baixa qualidade dos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo e, por

¹⁴ Art. 13. Para que possam ser adquiridos para a carteira do FUNDO, os Direitos Creditórios deverão atender os seguintes critérios de elegibilidade (“Critérios de Elegibilidade”): I- devem ser referentes a Devedores que, no momento da aquisição pelo FUNDO, não estejam inadimplentes com o FUNDO e/ou que não apresentem outros Direitos Creditórios vencidos e não pagos ao FUNDO; e II – a aquisição de Direitos Creditórios poderá ser contratada sem a coobrigação do cedente, mas o cedente sempre será responsável pela legitimidade e pela formalização dos Direitos Creditórios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

consequente, levantam fortes suspeitas quanto à adoção pelo Custodiante de procedimentos adequados na validação dos ativos cedidos ao Clássico FIDC.

33. Ocorre que a convicção quanto à ocorrência do ilícito imputado ao Citibank impõe a demonstração de que, por ocasião de sua cessão à carteira do fundo, o Custodiante permitiu o ingresso de ativos referentes a devedores já inadimplentes com o Clássico FIDC.

34. Não por outra razão, em 7.11.2018, proferi despacho solicitando à SIN a realização de diligências com o objetivo de explicitar que, ao tempo da cessão dos direitos creditórios ao fundo, não teria sido observado o critério de elegibilidade estabelecido no inciso II, do art. 13 do regulamento do Clássico FIDC.

35. Para tanto, a SIN utilizou-se dos dados da carteira do fundo relativos à data base de 13.9.2011, levantados pela SFI junto à equipe de trabalho do interventor nomeado para atuar junto à Oboé DTVM e refletidos nas planilhas “AtrasoFaturas.xlsx” e “Duplicidade.xlsx”, salvas em mídia às fls. 1.016 dos autos.

36. Entre todos os direitos creditórios cedidos em duplicidade, relacionados na planilha “Duplicidade.xlsx”, a Acusação selecionou os ativos adquiridos pelo Clássico FIDC em 13.9.2011 e os confrontou com as informações de vencimento e de titularidade constantes da planilha “AtrasoFaturas.xlsx”, tendo apontado diversos direitos creditórios cedidos na referida data base relativos a devedores inadimplentes com o fundo. Parte desses direitos creditórios já estaria, inclusive, vencida por ocasião de sua cessão ao fundo.

37. A partir deste levantamento, não resta dúvida quanto à ocorrência do ilícito imputado ao Custodiante, haja vista que, ao menos na data base de 13.9.2011, foram cedidos direitos creditórios em descumprimento ao critério de elegibilidade descrito no regulamento do Clássico FIDC.

38. Sustenta, no entanto, o Custodiante que, a partir das informações transmitidas pela Oboé DTVM quando da cessão dos direitos creditórios, não seria possível alcançar igual conclusão. Isso porque as datas de vencimento consideradas pela área técnica em sua avaliação não correspondem às aquelas indicadas na documentação enviada ao Citibank, as quais teriam sido adulteradas de modo a possibilitar a aquisição de tais ativos. Segundo o Citibank, as informações originalmente transmitidas pela cedente estariam descritas na planilha “Duplicidade.xlsx”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

39. De fato, ao analisar a referida planilha, verifica-se que, em relação aos direitos creditórios cedidos em 13.9.2011, os devedores aos quais correspondiam tais ativos não possuíam nenhuma dívida vencida e não paga com o fundo naquela data. Com efeito, em todos os casos selecionados a partir da planilha “Duplicidade.xlsx”, as dívidas anteriores mantidas por tais devedores teriam sido cedidas ao fundo em 16.8.2011 e teriam vencimento em 15.9.2011.

40. A própria planilha “AtrasoFaturas.xlsx”, da qual foram extraídas as informações de vencimento e de titularidade que levaram a Acusação a concluir pela inobservância do critério de elegibilidade, indica duas datas de vencimento distintas, a primeira delas coincidente com aquela constante da planilha “Duplicidade.xlsx” – supostamente aquela originalmente informada pela cedente por ocasião da cessão – e a segunda nomeada “Data_Vencimento_Fatura”, esta sim reproduzindo as informações consideradas pela Acusação e indicando a existência de dívida prévia já vencida.

41. A reforçar sua alegação quanto à manipulação das informações repassadas pela cedente, o Citibank mencionou comunicação enviada em 8.5.2012 pelo liquidante nomeado para atuar junto à Oboé DTVM segundo a qual “*as informações anteriormente encaminhadas a V.S^{as}. pela administração da Oboé Card, como cedente dos créditos, continham vencimentos irreais e fictícios*” (fls. 373).

42. Em que pese à verossimilhança de tais alegações, a sugerir que as informações repassadas pela Oboé DTVM e consideradas pelo Custodiante para validação dos critérios de elegibilidade foram adulteradas, não se encerra neste ponto a análise de sua responsabilidade.

43. Como exposto inicialmente neste voto, o propósito regulatório ao conferir à instituição custodiante o papel de *gatekeeper* é agregar à estrutura dos fundos de investimentos nível independente de controle e, à vista disso, estimular a adoção de boas práticas de governança. Para tanto, é imprescindível que, no exercício de suas atribuições, os prestadores de serviços – entre os quais o custodiante – mantenham procedimentos de verificação autônomos, especialmente em estruturas potencialmente conflituosas.

44. Não me parece ter sido esta a conduta adotada pelo Citibank na validação dos critérios de elegibilidade dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC.

45. Ao descrever as circunstâncias em que eram realizadas as operações de cessão de direitos creditórios ao Clássico FIDC, o Citibank esclareceu que, definidas as condições da cessão, pactuadas entre a Oboé Card e a Oboé DTVM, a administradora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

enviava instrução ao Custodiante solicitando o processamento da operação e, concomitantemente, a cedente encaminhava arquivo eletrônico com a lista de direitos creditórios a serem cedidos¹⁵.

46. Era com base nessas informações, repassadas, respectivamente, pela Oboé DTVM e pela Oboé Card, que o Citibank conduzia a verificação do primeiro critério de elegibilidade, a qual envolvia a parametrização do sistema mantido pelo Custodiante, de modo que, *“durante a rotina de processamento do arquivo de cessão, não [fossem aceitos] direitos creditórios de sacados que [possuíssem] títulos vencidos e não pagos com o fundo, na data em que a cessão é processada”* (fls. 351-373)¹⁶.

47. Não havia qualquer procedimento independente de validação das informações transmitidas pela Oboé Card a partir dos arquivos eletrônicos por ela preenchidos. Para avaliar se os créditos a serem cedidos ao Clássico FIDC eram elegíveis nos termos de seu regulamento, o Custodiante valia-se tão somente de documento produzido pela própria cedente dos direitos creditórios.

48. Nesse sentido, representantes do Citibank reconheceram em assembleia geral de cotistas realizada em 17.11.2011 que o Custodiante *“confiava em relatórios e declarações feitos pela cedente dos direitos creditórios”*, acrescentando, ainda, que *“o único critério de elegibilidade (...) verificado pelo Citibank era a natureza do crédito, que deveria ser oriundo de cartão de crédito (...)”* (fls. 523-533).

49. Insisto em ressaltar a relevância da manutenção de procedimentos de verificação autônomos pelos prestadores de serviço contratados pelo fundo, especialmente quando

¹⁵ Destaque-se o seguinte trecho da resposta apresentada pelo Citibank ao Ofício 52/2011: *“(i) Inicialmente, sempre que o cedente tem a intenção de ceder créditos, é feito o contato com o administrador e gestor dos FIDC (Oboé DTVM S.A.) para negociar as condições para o negócio, envolvendo, entre outros, montante a ser cedido, taxa de desconto e data da liquidação. Nesta etapa, o Custodiante não participa de nenhum procedimento, uma vez que são atos de gestão do fundo. (ii) Assim que as condições são definidas, o administrador envia instrução ao Custodiante solicitando o processamento de lote de direitos creditórios, informando nesta instrução as condições pactuadas com o cedente. (iii) Em paralelo, o cedente envia ao Custodiante um arquivo, padrão CNAB, com a lista de direitos creditórios a serem cedidos, já previamente validados em relação às condições de cessão a serem observadas pelo cedente. (iv) O Custodiante, de posse da instrução enviada pelo administrador e do arquivo com a lista de direitos creditórios oferecida pelo cedente, efetua o processamento da cessão, que inclui a verificação dos critérios de elegibilidade e cálculo do valor presente com base na taxa de desconto informada. (...)”*

¹⁶ Por sua vez, em relação ao segundo critério de elegibilidade, *“[o] Custodiante verifica[va] o cumprimento deste critério através da análise das condições em que o contrato de cessão foi firmado entre o fundo e o cedente, confirmando que o contrato possui cláusulas que responsabilizam o cedente pela legitimidade e formalização dos direitos creditórios”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

estamos diante de estrutura altamente concentrada, em que diversas atribuições são desempenhadas por um mesmo participante ou por partes a ele relacionadas – tal como era a estrutura do Clássico FIDC.

50. Isso não significa de forma alguma “*exigir da custodiante que, na validação dos critérios de elegibilidade, tivesse realizado uma prévia verificação de lastro*” (fls. 1026), conforme sustenta em sua defesa o Citibank. Por certo, estamos diante de atribuições distintas conferidas à instituição custodiante: a primeira voltada a impedir o ingresso na carteira do FIDC de direitos creditórios não elegíveis à luz dos critérios previstos em seu regulamento e aceitos pelos cotistas; e a segunda visando assegurar a existência, a titularidade e o montante dos créditos cedidos ao fundo, conforme será analisado na seção seguinte deste voto.

51. A ilustrar tal distinção, considere-se a hipótese de a instituição custodiante “vetar” o ingresso de direito creditório que não preenche os critérios de elegibilidade descritos no regulamento do fundo, mas cuja documentação comprobatória demonstre a perfeita constituição do lastro.

52. O que se esperava, portanto, do Citibank em relação à verificação da elegibilidade dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC era que este prestador de serviço mantivesse controle eficiente – e não ancorado em informações transmitidas pela própria cedente dos créditos – de modo a certificar-se que não fossem adquiridos ativos referentes a devedores que mantinham dívida já vencida com o fundo.

53. Por estas razões, devo concordar com a Acusação quando afirma que houve falhas nos procedimentos adotados na validação dos critérios de elegibilidade previstos no regulamento do Clássico FIDC.

II.2. FALHA NA VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CLÁSSICO FIDC

54. Passo então a analisar a segunda acusação imputada ao Custodiante, envolvendo a conferência da documentação que evidenciava o lastro dos créditos integrantes da carteira do Clássico FIDC.

55. Conforme relatado pela SIN, a verificação do lastro dos direitos creditórios cedidos ao fundo era conduzida por prestador de serviço especialmente contratado pelo Custodiante para este fim, a partir de conferência amostral, observados os procedimentos descritos no regulamento do Clássico FIDC.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

56. Esclareça-se que a própria Acusação reconhece que está sob análise não a simples delegação desta atividade a terceiro contratado, mas a responsabilidade administrativa do Custodiante pela adequação do procedimento adotado pelo prestador de serviço.

57. Nesse sentido, a área técnica ponderou, inclusive, a incidência do princípio da retroatividade benigna no presente caso, haja vista que, após a edição da Instrução CVM nº 531/13, passou-se a admitir expressamente a possibilidade de contratação de terceiro para a verificação de lastro dos direitos creditórios, em linha com a manifestação de voto apresentada pelo Diretor Pablo Renteria no Caso FIDC Union.

58. Dito isto, estou certo de que os elementos colhidos ao longo da Inspeção conduzida pela SFI justificam os questionamentos suscitados pela área técnica a respeito do procedimento de verificação de lastro mantido pelo Custodiante, uma vez que a situação dos ativos integrantes carteira do Clássico FIDC – em especial a, já mencionada, alta taxa de inadimplência e a existência de créditos em duplicidade – não reflete problemas pontuais ou isolados em relação a determinados direitos creditórios, mas a “*completa deterioração dos ativos*”¹⁷, tal como sinalizado pela equipe de intervenção que atuou junto à Oboé DTVM.

59. Justamente por não se tratar de situação pontual, era de se esperar que, mesmo por procedimento amostral, a conferência dos documentos comprobatórios do lastro dos direitos creditórios apontasse a existência de créditos vencidos ou em duplicidade na carteira do Clássico FIDC. Não obstante, nenhum dos relatórios trimestrais produzidos pelo prestador de serviço contratado pelo Citibank apontou qualquer inconsistência no lastro dos ativos cedidos ao fundo¹⁸.

60. Não poderia ser diferente se consideramos os procedimentos adotados pelo prestador de serviço contratado pelo Citibank, os quais – para minha surpresa – não

¹⁷ Vale esclarecer que a alta taxa de inadimplência dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC já era patente mesmo antes da decretação da intervenção da Oboé DTVM pelo BACEN. Em levantamento realizado pela equipe de intervenção, verificou-se que, em 13.9.2011, 14.688 das 96.115 faturas cedidas ao fundo apresentavam atraso de mais de 721 dias. Da mesma forma, foram identificadas 22.528 faturas cedidas em duplicidade. Não se poderia argumentar, portanto, que a situação se deteriorou após a decretação da intervenção.

¹⁸ A pedido da CVM, foram encaminhados pelo Citibank os relatórios relativos ao 3º e 4º trimestres de 2010 e ao 1º e 2º trimestres de 2011, constantes de mídia acostada às fls. 522 dos autos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

envolviam a análise das faturas dos cartões de crédito que serviam de lastro aos direitos creditórios cedidos ao fundo.

61. Ao ser questionado pela SFI “*como a instituição procede à verificação do lastro dos direitos creditórios*”¹⁹, o Custodiante descreveu o procedimento por ele adotado nos seguintes termos (fls. 326-327):

CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS:

(i) Obtenção da base de dados do Custodiante, contendo a composição analítica dos direitos creditórios de titularidade do Fundo, utilizada para extração da amostra de títulos a serem selecionados e analisados, conforme metodologia prevista no regulamento do fundo.

(ii) Obtenção da carteira sintética do Fundo na data-base escolhida, fornecida pelo Custodiante, contendo, inclusive, o valor contábil atualizado dos direitos creditórios para fins de confrontação dos valores informados na base de dados analítica.

(iii) Confronto dos dados do contrato de prestação de serviços efetuados pela cedente com os sacados com as informações contidas na amostra selecionada, com respeito a:

- Número do contrato/fatura;
- Nome do sacado
- Tipo do produto;
- Data de vencimento.

(iv) verificação da manutenção, pela cedente, dos documentos abaixo, referentes aos direitos creditórios de titularidade do fundo para a amostra selecionada:

- Contrato de prestação de serviços.
- Autorização do cliente para emissão do cartão.

62. Tal procedimento encontra-se igualmente descrito nos relatórios trimestrais elaborados pelo prestador de serviço contratado pelo Citibank.

63. Destaque-se que em relação à análise descrita no item (iii) acima, à exceção do primeiro relatório apresentado pelo contratado, referente ao 3º trimestre de 2010, todos os demais relatórios trimestrais informam terem sido confrontadas as informações constantes da base de dados do Custodiante com os dados dos contratos de prestação de serviços²⁰. Isto é, ao menos por ocasião das verificações realizadas no 4º trimestre de 2010 e nos 1º e 2º trimestres de 2011, o documento comprobatório dos créditos cedidos

¹⁹ Ofício/CVM/SFI/GFE-2/Nº052/2011.

²⁰ Nesse sentido, destaque-se o seguinte trecho do relatório, idêntico para os três trimestres mencionados: “Nossas constatações Confrontamos as informações contidas na base de dados dos direitos creditórios, disponibilizada no Procedimento A, com as respectivas informações dos contratos de prestação de serviços e não identificamos exceções” (fls. 522).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

ao fundo – qual seja, a fatura de cartão de crédito – sequer teria sido analisado por este prestador de serviço.

64. Por sua vez, de acordo com o conteúdo do relatório referente ao 3º trimestre de 2010, nesta primeira verificação teriam sido examinados não os contratos de prestação de serviço, mas sim os “dados dos cartões de débito/crédito”, entre os quais o “número do cartão” e o “valor da parcela”.

65. Ao que parece, portanto, o primeiro procedimento de verificação de lastro conduzido no âmbito do Clássico FIDC teria sido diferenciado. Também apontam nesse sentido as declarações prestadas por pessoas ligadas ao Grupo Oboé a respeito do repasse de informações e documentos solicitados pelo prestador de serviço, segundo as quais somente em uma primeira oportunidade teriam sido solicitadas cópias das faturas de cartão de crédito que lastreavam a carteira do fundo, após o que o terceiro contratado teria se limitado a analisar os contratos de prestação de serviço celebrados com a Oboé Card.

66. Sobre o tema, ressalto os seguintes trechos dos aludidos depoimentos:

(...) b) em relação ao Clássico FIDC, os documentos solicitados consistiam do contrato firmado entre a Oboé Card e a empresa contratante do serviço do pagamento de folha de salários através de cartão e a tela de desbloqueio do cartão pelo usuário, para garantir que o cartão estivesse ativo); c) ainda em relação ao Clássico FIDC, recorda-se que somente no primeiro trabalho de verificação de lastro (...), em meados de 2010, é que o auditor solicitou cópia de algumas faturas de cartão de crédito e os registros de alguns clientes junto ao SPC/SERASA, mas tal solicitação de documentos não voltou a ser feita nos trabalhos posteriores; (...)

(Depoimento prestado em 30.5.2012 por A.C.B.P, Gerente do Ambiente de Gestão de Ativos da Oboé DTVM)

(...) pelo que se recorda, somente em uma oportunidade, provavelmente no início de funcionamento do Clássico FIDC, é que foram solicitadas ao depoente cópias de faturas que seriam enviadas para o auditor de lastro; depois disso, não mais lhe foram solicitadas cópias de faturas de clientes com esse propósito; também nunca foram solicitadas ao depoente informações sobre o nível de inadimplência da carteira, para fins de atendimento à empresa contratada para verificação de lastro ou mesmo para o auditor independente que analisava o balanço do Clássico FIDC (...)

(Depoimento prestado em 1.6.2012 por S.S.M, ex-funcionário da área contábil-financeira da Oboé Card)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

67. É patente, a meu ver, a insuficiência dos procedimentos conduzidos por terceiro contratado pelo Custodiante para fins de verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC.

68. Não há como conceber que tal atividade pudesse ser adequadamente desempenhada sem a análise das faturas dos cartões de crédito, documento fundamental para comprovar a existência, a titularidade e o montante dos créditos cedidos ao fundo, bem como permitir o controle pelo Custodiante dos ativos integrantes de sua carteira, possibilitando, por exemplo, a identificação de créditos cedidos em duplicidade, tal como se verificou no presente caso.

69. Discordo do argumento do Citibank no sentido de que o contrato de prestação de serviço e a autorização do titular do cartão para sua liberação “*ofereciam segurança sobre a existência da relação contratual de utilização do cartão de crédito, sendo inerente a esta relação a constituição periódica de direitos creditórios*” (fls. 782). A meu ver, seria perfeitamente possível que celebrado o contrato de prestação de serviço e liberada a utilização do cartão de crédito por seu titular este último não realizasse operações de modo a originar direitos creditórios a serem cedidos pela Oboé Card.

70. Estou certo de que a adequada verificação de lastro pressupunha, neste caso, a conferência das faturas de cartão de crédito.

71. Vale destacar, inclusive, que o procedimento adotado na verificação do lastro dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC destoa daquele conduzido pelo mesmo prestador de serviço na análise da carteira do Multicred FIDC.

72. Conforme descrito nos relatórios trimestrais relativos a este fundo²¹, disponíveis em mídia às fls. 522, as informações da amostra de créditos, selecionada aleatoriamente

²¹ Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho do relatório de inspeção, descrevendo parte do procedimento de verificação conduzido pelo prestador de serviço contratado pelo Citibank junto ao Multicred FIDC: “*Procedimento C: ‘Confronto das Cédulas de Crédito Bancário (CCB) com as informações contidas na base de dados dos direitos creditórios disponibilizada no Procedimento A, com respeito a’: número da CCB; nome do sacado; Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sacado; tipo de produto; ano de fabricação e modelo; marca e modelo; data de vencimento; quantidade de parcelas; valor do bem; valor financiado; e valor da parcela. Procedimento D: ‘Verificação da manutenção, pelos cedentes, dos documentos selecionados a seguir, referentes aos direitos creditórios de titularidade do Fundo para a amostra selecionada para o Procedimento A’. Documentos selecionados: CCB; autorização do devedor para desconto em folha de pagamento, caso seja empréstimo consignável; CPF; RG; comprovante de residência do devedor; documentos que comprovem a margem consignável, em caso de empréstimo consignável; parecer emitido pelo analista de crédito; e apólice de seguro*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

nos termos do regulamento do fundo, eram confrontadas com as próprias cédulas de crédito bancário (“CCBs”) representativas dos direitos creditórios – isto é, com a documentação comprobatória do lastro.

73. Além da CCB, eram disponibilizados para análise pelo prestador de serviços: (i) a autorização do devedor para desconto em folha de pagamento, em caso de empréstimo consignável; (iii) o CPF, RG e comprovante de residência do devedor; (iv) os documentos aptos a comprovar a margem consignável; (v) o parecer emitido pelo analista de crédito; e (vi) a apólice de seguro.

74. Chama atenção a diferença na forma como era conduzido o procedimento de verificação de lastro em relação a cada um dos FIDCs. Não à toa as investigações levadas a cabo no curso do presente processo em relação ao Multicred FIDC não resultaram na formulação de acusação em face do Custodiante.

75. Aproveito para ressaltar que, à época dos fatos, a regulamentação vigente não exigia da instituição custodiante a conferência da documentação comprobatória do lastro já no momento de cessão dos direitos creditórios²², de modo que era justamente a verificação trimestral a ocasião para confrontar as informações constantes da base de dados do custodiante com os documentos que evidenciariam a existência de tais direitos creditórios e, por conseguinte, permitiriam atestar as características do crédito cedido ao fundo.

76. Como exposto na introdução deste voto, as atribuições conferidas à instituição custodiante por força da regulamentação editada por esta autarquia têm por objetivo agregar níveis independentes de controle, estimular boas práticas de governança e controles internos e, assim, mitigar riscos de fraude.

77. Diante disto, afasto, de plano, a alegação do Custodiante de que “*quando se está diante de uma situação de fraude, em que agentes atuam deliberadamente para burlar as*

²² Destaque-se que a redação original do inciso I do art. 38 da ICVM 356/01 não previa a periodicidade com que verificação de lastro deveria ser realizada pelo custodiante. Contudo, quando lido em conjunto com o disposto nos incisos III e IV do §3º do art. 8º, conduzia à interpretação de que a verificação de lastro ocorreria trimestralmente, sendo divulgada no demonstrativo trimestral do fundo, conforme destacado no edital de audiência pública SDM nº 05/2012 Com a reforma promovida pela ICVM 531/13, passou-se a dispor expressamente que a atividade de verificação de lastro deve ser desempenhada pela instituição custodiante em dois momentos distintos: “o mais próximo possível do ingresso do direito creditório no fundo” (§12, art. 38) e “durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral” (inciso III, art. 38).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

regras e obrigações impostas, [seria] muito difícil assegurar-se que a atuação regular dos outros agentes envolvidos, os gatekeepers, impeça a prática de fraude” (fls. 782).

78. A uma porque é justamente a repartição das atribuições inerentes ao funcionamento do fundo entre diferentes prestadores de serviços, independentes entre si, que inibe a atuação de outros agentes que busquem valer-se de sua posição para a prática de atos fraudulentos. Repita-se, foi com este objetivo que se buscou adicionar outro *gatekeeper* – para além do administrador fiduciário – na estrutura dos fundos: estimular a manutenção de controles mútuos e eficientes.

79. A duas porque esta linha de argumentação foi construída “de trás para frente”, isto é, analisando “pelo retrovisor” a acusação formulada pela SIN. À época dos fatos, conforme alegado, o Custodiante não tinha conhecimento das fraudes conduzidas pelo Grupo Oboé, notadamente a adulteração de informações relativas aos direitos creditórios cedidos ao fundo, de modo que a suposta “ausência de utilidade” na verificação das faturas de cartão de crédito, que, por serem documentos produzidos pela própria Oboé Card, poderiam ser igualmente fraudados, em nada justifica a falha no procedimento adotado pelo Citibank para verificação do lastro.

80. Por estas razões, entendo terem restado largamente evidenciadas as falhas no procedimento de verificação de lastro adotado pelo Custodiante em relação ao Clássico FIDC.

II.3. LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CLÁSSICO FIDC PELO RESULTADO LÍQUIDO (NETTING)

81. A terceira irregularidade a ser apurada diz respeito à forma de liquidação das operações do Clássico FIDC, que, em determinadas ocasiões, teria se dado pelo resultado líquido entre a “baixa” de direitos creditórios da carteira do fundo e a aquisição de novos ativos junto à cedente (*netting*), o que, na visão da Acusação, importaria violação ao disposto no inciso III, do art. 38 da ICVM 356/01.

82. Ao analisar a liquidação dos direitos creditórios cedidos ao fundo, a SFI verificou que, dentre as 63 cessões de créditos celebradas no período de set/2010 a set/2011, somente em 16 casos a liquidação dos ativos se deu pelo “Valor Integral”, sendo que em todas as demais ocasiões a liquidação foi realizada pelo “Resultado Líquido” entre o montante de aquisição de novos direitos creditórios e a “baixa” de créditos cedidos anteriormente, conforme indicado na planilha “Cessões_Geral_ClassicoFIDC.xlsx” (fls. 522).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

83. Apurou-se, ainda, que a liquidação pelo “*netting*” refletiria o modelo operacional adotado no âmbito do Clássico FIDC. Conforme depoimento prestado por ex-funcionário da Oboé Card, S.S.M., os créditos cedidos ao fundo apresentariam um “ciclo de vida” curto, sendo periodicamente renovados, *“ou seja, sempre que havia o vencimento de um lote de faturas que estava na carteira do fundo, este lote retornava à Oboé Card e, ato contínuo, um novo lote de faturas era gerado e cedido ao fundo”*, de modo que o fluxo financeiro entre o fundo e a Oboé Card – concomitantemente cedente e agente de cobrança – decorreria da compensação entre o valor a ser pago pelo Clássico FIDC pelos novos ativos e o montante devido pela Oboé Card em razão da “reaquisição” de parte dos créditos cedidos ao fundo.

84. Segundo a Acusação, este modelo operacional permitiria o alongamento dos prazos de vencimento dos direitos creditórios cedidos ao fundo e, por conseguinte, agravaria o seu risco de crédito. Além disso, de acordo com depoimentos de pessoas ligadas à Oboé DTVM, o referido modelo ocultaria o índice de inadimplência do Clássico FIDC, visto que *“no mesmo dia, o fundo comprava novas safras de crédito da Oboé Card, e esta, por sua vez, recomprava do fundo as operações que estavam vencendo”* (fls. 566-568)

85. Para a SIN, ao permitir a liquidação dos direitos creditórios pelo resultado líquido, sem que houvesse, portanto, o ingresso de recursos no patrimônio do fundo decorrente do pagamento das faturas de cartão de crédito, o Citibank teria contribuído para a alta taxa de inadimplência da carteira do Clássico FIDC.

86. Discordo da lógica acusatória por duas razões.

87. Em primeiro lugar, porque se, de fato, assumíssemos que ao longo do funcionamento do Clássico FIDC ocorria, sistematicamente, a renovação periódica dos créditos vencidos ou prestes a vencer, integrantes da carteira do fundo, não teriam sido identificadas cessões de direitos creditórios relativos a devedores já inadimplentes com o fundo, conforme descrito na seção II.1. deste voto, visto que, ao tempo da aquisição do novo ativo, o crédito anterior daquele devedor, já vencido, teria sido readquirido pela Oboé Card e “baixado” da carteira do fundo.

88. Em segundo lugar, porque, a meu ver, a “contribuição” do Citibank para a alta taxa de inadimplência da carteira do Clássico FIDC adviria das falhas identificadas na validação dos critérios de elegibilidade e na verificação de lastro dos direitos creditórios cedidos ao fundo – estas sim a possibilitar a existência de ativos de baixa qualidade na



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

carteira do fundo – e não do fato de o Custodiante ter compensado os valores devidos à Oboé Card em razão de operações simultâneas de “recompra” de créditos e cessão de novos ativos junto ao fundo.

89. Em outras palavras, a “fragilidade” da estrutura operacional do Clássico FIDC subsistiria não na recompra (sem deságio) de parte dos direitos creditórios cedidos ao fundo pela cedente – que, em tese, passaria a assumir o risco do processo de cobrança dos devedores –, mas na aquisição de direitos creditórios em inobservância aos critérios fixados no regulamento do fundo.

90. Alegou, ainda, a Acusação que o Custodiante teria descumprido as disposições do “Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre o Clássico FIDC e a Oboé Card, no qual figurou como interveniente anuente. Isso porque, nos termos do item II da Cláusula V do referido contrato, “[t]odos os pagamentos devidos nos termos deste Contrato dever[iam] ser feitos em moeda corrente nacional, por meio de recursos imediatamente disponíveis, mediante crédito em conta corrente”, não havendo qualquer previsão de liquidação dos direitos creditórios por meio da compensação de valores.

91. Em relação a este ponto, estou de acordo com a defesa quando esta afirma que a existência de disposição contratual prevendo a liquidação das operações de aquisição de direitos creditórios em moeda corrente nacional não impediria o Custodiante de compensar o valor a ser pago pelos ativos adquiridos com eventual débito mantido junto ao fundo pela cedente. Inexistindo previsão contratual vedando a compensação de valores entre as partes, o encontro de contas poderia ser oposto por qualquer das partes, nos termos do disposto nos arts. 368²³ e 375²⁴ do Código Civil.

92. Por estas razões, afasto a acusação de violação ao disposto no art. 38, inciso III, da ICVM 356/01.

²³ Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

²⁴ Art. 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluïrem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

II.4. DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COBRANÇA E GUARDA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AOS FIDCs

93. Passo, por fim, à análise da última acusação formulada pela SIN, envolvendo a delegação das atividades de cobrança e guarda dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC e ao Multicred FIDC.

94. De antemão, ressalto que o enfoque da área técnica ao tratar destas acusações foi a própria delegação das atividades e não a adequação dos procedimentos adotados pelos prestadores de serviço contratados pelo Custodiante, destoando, portanto, das considerações apresentadas em relação à atividade de verificação de lastro.

95. A fim de defender a impossibilidade de delegação das atividades de cobrança e guarda dos direitos creditórios aos próprios cedentes – neste caso, a Oboé Card e a Oboé CFI -, a Acusação sustenta que, mesmo antes da reforma promovida pela ICVM 531/13, a delegação de atividades privativas de instituição custodiante a terceiros não registrados perante a CVM para exercício da atividade de custódia já estaria em desacordo com a ICVM 356/01.

96. Nesse sentido, fez referência ao entendimento manifestado pela Procuradoria Federal Especializada – PFE em parecer elaborado a pedido da SIN no curso do Proc. CVM nº RJ2010/178711, bem como às decisões proferidas pelo Colegiado no julgamento dos Casos FIDC Union e FIDC Panamericano.

97. Sobre o tema, alinho-me ao entendimento manifestado pela maioria do CRSFN no julgamento de recurso interposto no âmbito do Caso FIDC Union no sentido de que, de acordo com a redação original da ICVM 356/01, não havia vedação expressa à delegação de atividades pela instituição custodiante²⁵.

98. Ainda que posteriormente se tenha vedado a delegação de tais atividades ao cedente dos direitos creditórios, nos termos do §7º do art. 38 da ICVM 356/01, é certo

²⁵ A esse respeito, o Conselheiro Relator Carlos Pagano ressaltou que “(...) até a entrada em vigor da ICVM 531/2013, datada de 6 de fevereiro de 2013, não havia clareza a respeito da proibição da cessão da guarda física dos documentos comprobatórios pelos cedentes. Ainda que essa prática tenha sido duramente rechaçada pela revisão da ICVM 356/2001 por meio das alterações trazidas pela ICVM 531/2013, não é possível considerar que, à época dos fatos, os custodiantes que operavam no mercado deveriam considerar irregular tal delegação. Decidir assim implica em realizar um juízo de valor ignorando a evolução histórica da regulamentação e da prática do mercado de fundos de investimento, além de representar um claro juízo retroativo em prejuízo do administrado, o que não seria permitido pelo sistema jurídico pátrio”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

que tal previsão não poderia retroagir para atingir fatos ocorridos antes da entrada em vigor da ICVM 531/13.

99. Não tenho dúvidas de que a concentração de funções por um mesmo prestador de serviço ou por partes a ele relacionadas compromete a boa governança dos fundos, favorecendo situações de conflito de interesse. A despeito da maior eficiência e segurança do regime regulatório ora em vigor, entendo não ser possível responsabilizar o Custodiante por prática que, à época dos fatos objeto do presente processo, não era vedada pela regulamentação.

100. Por fim, ressalto que, muito embora haja indícios de que o procedimento de cobrança descrito nos regulamentos dos FIDCs não era observado pelos “agentes de recebimento e cobrança” contratados pelo Custodiante, a qualidade dos serviços prestados pela Oboé Card e pela Oboé CFI não foi objeto de considerações adicionais pela Acusação, motivo pelo qual entendo não ser oportuno inaugurar esta análise em sede de julgamento.

III. CONCLUSÕES

101. No que diz respeito à dosimetria das penalidades a serem aplicadas, considerarei como atenuante a ausência de antecedentes do acusado.

102. De outra parte, considerarei como agravante a relevância da posição ocupada pelo Citibank na estrutura dos Clássico FIDC, não somente em razão do papel de *gatekeeper* conferido pela regulamentação à instituição custodiante, mas principalmente pelo fato de que, em uma estrutura inerentemente conflituosa, com atribuições sendo desempenhadas por sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, a presença do Citibank agregava credibilidade às atividades do fundo e, por conseguinte, representava importante fator de atração de investidores.

103. Também serão levados em conta como agravantes da conduta do acusado os enormes prejuízos suportados pelos cotistas diretos e indiretos dos Clássico FIDC²⁶, para

²⁶ Os prejuízos suportados pelo patrimônio do Clássico FIDC teriam impactado não somente os 124 cotistas do fundo, entre os quais 112 cotistas pessoas físicas, como também, indiretamente, os 342 cotistas do Erudito FIC FIM CP, entre os quais 318 cotistas pessoas físicas. Isso porque boa parte do patrimônio líquido do fundo estava exposto aos riscos do Clássico FIDC, visto que 17,71% era composto por cotas deste FIDC e 41,39% de cotas do Regente FIM CP, o qual, por sua vez, tinha 77,88% de seu patrimônio em cotas do Clássico FIDC.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

os quais teriam contribuído as falhas verificadas nas atividades sob a responsabilidade do Custodiante.

104. Considerando tais circunstâncias, bem como as penalidades impostas à instituição custodiante nos precedentes sobre o tema²⁷, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto em relação ao Citibank DTVM S.A.:

- (i) pela sua **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em razão da inobservância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso II da ICVM 356/01;
- (ii) pela sua **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em razão das falhas na verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso I da ICVM 356/01;
- (iii) pela sua **absolvição** da acusação de violação ao disposto no art. 38, inciso III da ICVM 356/01, em razão da liquidação dos direitos creditórios do Clássico FIDC pelo resultado líquido e não financeiramente; e
- (iv) pela sua **absolvição** da acusação de violação ao disposto no art. 38, incisos IV e VI, da ICVM 356/01, em razão da delegação das atividades de cobrança e guarda física dos direitos creditórios cedidos aos FIDCs.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

²⁷ No Caso FIDC Panamericano, o Colegiado condenou o custodiante à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao art. 38, inciso I, da ICVM 356/2001, considerando a indevida subcontratação de terceiro não autorizado para a análise da documentação que evidenciava o lastro dos créditos integrantes da carteira dos fundos. Por sua vez, no que diz respeito ao Caso FIDC Union, mesmo após o julgamento do recurso interposto ao CRSFN, foi mantida a condenação da instituição custodiante à penalidade de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por não manter atualizada e em perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios, em infração ao art. 38, inciso V, da ICVM 356/2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2015/13791

Reg. Col. nº 0347/2016

Acusado: Citibank DTVM S.A.

Assunto: Falha no desempenho das atividades sob a responsabilidade da instituição custodiante (art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM 356/01).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

1. No presente processo administrativo sancionador apura-se a responsabilidade do Citibank por irregularidades no desempenho das atividades de custodiante do Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditório e do Oboé Multicred – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, à luz do art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM 356/01, com redação dada à época dos fatos. A análise do caso perpassa, obrigatoriamente, a discussão quanto à possibilidade ou não de delegação daquelas atividades.
2. Sobre o assunto, destaco inicialmente que no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5456, julgado em 20 de outubro de 2015, o Colegiado desta CVM concluiu pela impossibilidade da terceirização de atividades de custódia à empresa não registrada e condenou o Bradesco a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00, por delegar aos cedentes a atividade de guarda dos documentos que evidenciam o lastro dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, IV, da Instrução CVM nº 356/2001.
3. No mesmo sentido, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2011/10415, julgado em 02 de dezembro de 2014, o Colegiado desta CVM condenou o Itaú Unibanco S.A à pena de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao art. 38, inciso I, da Instrução CVM nº 356/2001, considerando a indevida subcontratação de terceiro não autorizado, a URC Assessoria



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Comercial S/C Ltda., para a análise da documentação que evidenciava o lastro dos créditos integrantes da carteira de fundos.

4. Dessa forma, é possível notar que a CVM, no julgamento de processos sancionadores anteriores, sustentou o entendimento da Acusação quanto ao impedimento à delegação de atividades de custódia de direitos creditórios a terceiro não registrado como custodiante, no período sob vigência da Instrução nº 356/2001, com redação anterior à Instrução CVM nº 531, de 6 de fevereiro de 2013.

5. Entendo, entretanto, que tal entendimento merece revisão.

6. Com efeito, ainda em outubro de 2005, muito antes dos fatos descritos neste processo, o Colegiado desta Autarquia já se manifestava categoricamente sobre a adequada interpretação do art. 38 da Instrução CVM nº 356/01 e inclusive propunha ajustes ao texto da norma. No âmbito de consulta objeto do Processo CVM nº RJ2004/6913, o então Presidente da CVM Marcelo Fernandez Trindade assim se manifestou sobre a verificação de lastro e atuação de terceiro contratado:

Interpretação razoável do art. 38 da Instrução CVM 356/01

Parece, assim, ser razoável adotar uma interpretação do inciso I do art. 38 da Instrução CVM 356/01 que, de um lado, não elimine os benefícios da verificação do lastro dos recebíveis pelo custodiante e, por outro, não imponha custos excessivos e desnecessários aos FIDC. Admitir-se-ia, desse modo, que em fundos em que haja expressiva diversificação de devedores, e significativo volume de créditos cedidos, a verificação do lastro dos recebíveis pelo custodiante (ou por terceiro contratado, sem delegação da responsabilidade administrativa) fosse feita por amostragem, segundo procedimentos descritos no regulamento ou no prospecto do FIDC.

7. Posteriormente, em maio de 2012, nos autos do Processo Administrativo nº RJ2011/12712, o Colegiado¹ acompanhou a manifestação da área técnica² e dispensou a obrigatoriedade do Banco Bradesco S/A, na qualidade de custodiante, desempenhar as atividades de guarda dos documentos comprobatórios e de cobrança dos direitos creditórios e ainda autorizou que tais serviços fossem terceirizados.

¹ Decisão proferida na reunião de Colegiado de 02 de maio de 2012 (http://www.cvm.gov.br/decisoes/2012/20120502_R1/20120502_D05.html).

² Considero relevante destacar o entendimento da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais traduzida no Memo/CVM/SIN/GIE/nº 62/2012, aprovado pelo Superintendente Francisco José Bastos Santos. Naquela oportunidade, enfatizou-se “que a terceirização, per si, não é o cerne dos problemas que afetam a indústria e sim a forma como as terceirizações foram efetivamente implementadas, materializando hipóteses de conflito de interesses, nas quais o originador e/ou o cedente dos direitos creditórios, ao realizar atividades típicas dos custodiantes de FIDC, fragilizaram a plataforma regulatória”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

8. De fato, o entendimento desta Comissão quanto à possibilidade de delegação das atividades viria a ser amplamente divulgado com o Edital de Audiência Pública SDM nº 05/12 e, em seguida, cristalizado nos termos dos §§ 6º a 10, do art. 38³, da Instrução CVM nº 356/01, incluídos pela Instrução CVM nº 531/13.

9. Entendo que, com o advento da Instrução CVM nº 531/13, a terceirização, que não era até então proibida, foi adequadamente tratada restringindo-a a determinadas atividades de custódia e sob determinadas condições, como resultado da observação das práticas positivas e negativas de mercado, conforme descritas no Relatório de Audiência Pública⁴.

10. É nesse contexto que analiso e discordo do entendimento da Procuradoria Federal Especializada da CVM, exarado no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/nº 129/2011, segundo o qual haveria impedimento jurídico à delegação da custódia de direitos creditórios, de determinado FIDC, a um terceiro não autorizado. Com efeito, nos termos da redação da norma vigente à época e dos precedentes citados acima, a delegação de atividades não só não era vedada pela norma como também era admitida expressamente pelo Colegiado desta Autarquia. De forma que qualquer acusação fundada exclusivamente na delegação de atividades do custodiante para terceiros deve ser julgada improcedente.

³ Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...)

§ 6º Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da documentação de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade.

§ 7º Os prestadores de serviço contratados de que trata o § 6º não podem ser:

I – originador;

II – cedente;

III – consultor especializado; ou

IV – gestor.

§ 8º A restrição mencionada no § 7º também se aplica a partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, aos participantes listados nos seus incisos I ao IV.

§ 9º Nos casos de contratação prevista no § 6º, o custodiante do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:

I – permitir o efetivo controle do custodiante sobre a movimentação da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo sob guarda do prestador de serviço contratado;

II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:

a) nos incisos II e III do caput, no que se refere à verificação de lastro dos direitos creditórios; e

b) nos incisos V e VI do caput, no que se refere à guarda da documentação.

§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9º devem:

I – constar do prospecto da oferta do fundo, se houver;

II – constar do contrato de prestação de serviços;

III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo na rede mundial de computadores, junto com as demais informações de que trata o art. 53-A;

⁴ Acessível em http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2012/sdm0512.html.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

11. Verifico, portanto, pertinentes as considerações do Conselheiro Carlos Gouvêa no julgamento do Recurso CRSFN nº 14.419, em 24 de abril de 2015:

Assim, percebe-se que, até a entrada em vigor da ICVM 531/2013, datada de 6 de fevereiro de 2013, não havia clareza a respeito da proibição da cessão da guarda física dos documentos comprobatórios pelos cedentes. Ainda que essa prática tenha sido duramente rechaçada pela revisão da ICVM 356/2001 por meio das alterações trazidas pela ICVM 531/2013, não é possível considerar que, à época dos fatos, os custodiantes que operavam no mercado deveriam considerar irregular tal delegação. Decidir assim implica em realizar um juízo de valor ignorando a evolução histórica da regulamentação e da prática do mercado de fundos de investimento, além de representar um claro juízo retroativo em prejuízo do administrado, o que não seria permitido pelo sistema jurídico pátrio.

Cabe destacar aqui que o caso presente não trata de uma conduta generalizada no mercado que, à época, já era contrária à legislação. O caso aqui trata de uma conduta generalizada que, à época, não era contrária à norma. Posteriormente à reforma da ICMV 356/2001, tal prática foi substancialmente restringida. Então, o caso presente não seria, como tantos outros trazidos a este Conselho, relacionado a uma mudança de entendimento jurisprudencial que vá de encontro a uma prática generalizada do mercado. O que temos aqui é uma efetiva mudança na regulamentação em momento posterior, sendo que o princípio administrativo da legalidade previsto no Art. 37 da Constituição Federal e no Art. 2º, parágrafo único, XIII da Lei nº 9784/1999, vinculantes a toda a Administração Pública, direta ou indireta, em todos os níveis federativos, impede a aplicação retroativa das normas legais ou infralegais em prejuízo dos administrados.

12. No presente caso, deve-se à inegável razoabilidade dessa interpretação o fato de que a terceirização se tornou prática do mercado constando inclusive dos regulamentos de FIDCs, levados a registro perante esta CVM e submetidos à apreciação dos cotistas. Claramente não havia, por parte dos custodiantes, a intenção de ocultar prática irregular.

13. Nada obstante, importa destacar que a delegação da atividade não exclui a responsabilidade administrativa do custodiante, fazendo-se necessário avaliar, em cada caso, como ele se desincumbiu dessa responsabilidade supervisionando a atuação daqueles que subcontratou ou a quem as atividades foram delegadas. Como bem salientado no voto condutor, *isso não significa que, diante de uma estrutura potencialmente conflituosa, com atividades concentradas em um único participante ou em sociedades do mesmo grupo econômico – tal como seria o caso dos fundos*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

administrados pela Oboé DTVM –, os prestadores de serviço “independentes” não dispusessem, já à época dos fatos, de mecanismos de controles capazes de mitigar os riscos decorrentes de tal estrutura, notadamente o risco de fraude. Ao contrário, tinham os mecanismos e também o dever de os utilizar.

14. Com acréscimo dessas razões, acompanho integralmente as considerações e as conclusões do Ilustre Diretor Relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR